

Droit administratif

Introduction

§1 - Définition générale du droit administratif

= Le droit spécifique de l'administration.

A) La notion de l'administration

L'administration est l'objet du droit administratif. On trouve de l'administration dans toutes structures organisées, il existe de l'administration privée et de l'administration publique. L'administration publique est l'objet du droit administratif.

1) L'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SENS ORGANIQUE

Au sens organique, l'Administration désigne l'ensemble des organes qui au sein des personnes morales de droit public exercent la fonction administrative (directeurs, présidents d'universités, maires, ministres...).

=> Ce sont bien évidemment les agents de l'administrations (personnes physiques) qui agissent. Certains de ces agents ont un statut de fonctionnaire quand d'autre ont un statut contractuel. Il existe aussi un troisième statut: les élus, titulaires d'un mandat.

L'expression « autorité administrative » désigne un organe ou agent de l'administration qui dispose en propre {qu'il tient de lui-même et non pas de la délégation de quelqu'un d'autre} d'une compétence décisionnaire (pouvoir de décision).

⚠ A ne pas englober dans la notion d'Etat l'administration publique (ils sont différents car l'Etat n'est qu'un des organes propres et n'est pas seulement une administration).

2) L'ADMINISTRATION PUBLIQUE AU SENS FONCTIONNEL

= la fonction administrative elle-même, pas des organes et des personnes mais bien l'activité administrative. Une définition négative de la fonction administrative est plus simple à donner qu'une positive. On peut dire que la fonction administrative est, au sein des 4 grandes fonctions de l'Etat, n'est ni législative, ni juridictionnelle, ni gouvernementale.

=> On peut tout de même relever que face à la densification des normes, la fonction administrative a fini par prendre un certain pouvoir.

Définition positive du doyen HAURIOU: « la fonction administrative a pour objet de gérer les affaires courantes du public en ce qui concerne l'exécution des lois et la satisfaction des intérêts généraux ».

= La fonction administrative rend les lois concrètement applicables et appliquées (décrets d'application, arrêtés d'application, circulaires).

L'un des rôles de l'administration est aussi la satisfaction de l'intérêt général de par le maintien de l'ordre mais encore la fourniture aux administrés (citoyens) de prestations (ex. Fourniture d'eau potable...).

La distinction entre les définitions organiques et fonctionnelles existent car les deux ne vont pas toujours de paire: il arrive souvent qu'un service public soit géré non pas par la personne publique qui en est responsable mais par une personne privée agissant par délégation des pouvoirs de la personne publique. Le service reste assuré par la personne publique et en fournit les grandes orientations mais le service quotidien est assuré par une société privée.

L'objet du droit administratif est donc à la fois le sens organique et fonctionnel. Le contentieux relève donc du juge administratif et donc du droit administratif.

B) L'idée de droit spécifique

Il y a une part de spécificité qui relève de l'essence même du droit administratif.

1) UN CRITÈRE DU DROIT ADMINISTRATIF STRICTO SENSU

Le droit administratif n'est pas tout le droit de l'administration publique, il n'est stricto sensu qu'une partie de ce droit, il n'est que le droit spécifique de l'administration. L'activité administrative est tantôt régie par des règles de droit privées et tantôt régie par des règles distinctes du droit privé. Ces règles distinctes du droit privé s'appliquant à l'activité administrative sont dites exorbitantes du droit commun.

=> Droit administratif = partie spécifique du droit qui s'applique à l'administration publique (les règles distinctes du droit privé qui viennent parfois s'appliquer aux administrations).

Exemple: Une commune qui veut un terrain pour un projet quelconque peut tant exproprier (droit administratif) que négocier directement l'achat avec le propriétaire (droit civil).

Ex. : Les services publics industriels et commerciaux (SPIC) (en opposition aux Services Publics Administratifs) ont la spécificité d'être en principe soumis au droit privé et à la compétence judiciaire, leur gestion relève donc en partie du droit privé quand bien même leur gestion relève de l'agent administratif et ce depuis **l'arrêt société commerciale de l'ouest africain du tribunal des conflits du 22 Janvier 1921** (affaire bac Eloka).

Précision: Le droit commun, du point de vue du droit dans son ensemble, est le droit privé (le droit administratif est donc un droit exceptionnel). Cependant, du point de vue du droit de l'administration publique, c'est le droit administratif qui devient le droit commun et le droit privé en devient un droit exceptionnel.

Il n'existe pas de critère permettant de savoir quel droit (privé ou administratif) s'applique à l'administration.

Certains auteurs ont cherché à en trouver un:

- Le critère de la puissance publique (doyen Hauriou): dès lors que la fonction administrative est exercée au moyen de prérogative de puissances publiques, c'est le droit administratif qui devrait s'appliquer vs. Exercice au moyen de procédés ordinaires, on applique le droit privé. Cependant, ce critère ne correspond pas à l'état du droit positif car beaucoup des contrats passés par l'administrations sont dits administratifs et donc soumis au droit administratifs.
- Le critère sur service public (Léon Duguit): Tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement des services publics relève du droit administratif. Ce critère a été réfuté par l'arrêt société commerciale de l'ouest africain.
- Le critère d'utilité publique (Marcel Waline) : à chaque fois que l'administration agit pour l'utilité publique, on applique le droit administratif. Sauf qu'en réalité, l'administration agit toujours pour l'utilité publique, c'est à la fois le fondement et la limite de son action.
- Le critère organique: lorsque la fonction administrative est exercée par une personne publique, on applique le droit administratif et lorsqu'elles le sont par une personne privée, on applique le droit privé. Cependant, ce critère ne rend pas compte du droit positif en vigueur.

=> A défaut de critère général, la question n'a qu'une réponse spécifique à un cas précis.

2) LE CONTENU ESSENTIEL DE LA SPÉCIFICITÉ DU DROIT ADMINISTRATIF

Il y a une essence de la spécificité administrative, que l'on retrouve dans tous les pays et dans toutes les époques. En effet, le droit civil repose sur l'idée d'égalité, de consentement: une personne ne peut pas imposer à une autre des obligations contre sa volonté. En revanche, le droit administratif est un droit inégalitaire: il a pour raison d'être de donner à l'administration les moyens de faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Des pouvoirs spéciaux sont donc conférés à l'administration pour pouvoir imposer sa volonté aux administrés.

Précision: Un droit inégalitaire n'est pas un droit déséquilibré. Un droit inégalitaire peut être équilibré: d'un côté des privilèges sont donnés à l'administration quand de l'autre des droits et des garanties sont assurés aux administrés.

§2- Les caractères du droit administratif français

A) Le caractère jurisprudentiel

La jurisprudence est source de toutes les branches de droit. Ce qui est propre au droit administratif est que **la jurisprudence est la source fondamentale du droit administratif**.

On trouve plusieurs raisons à ce caractère jurisprudentiel:

- Historique: c'est un droit qui a été créé par le juge (le CE) et non pas par le législateur.
- Les fondements de ce droit restent aujourd'hui jurisprudentiels. Bien qu'il existe aujourd'hui des Codes (propriété de la personne publique, fonction publique...) donc des sources textuelles, la jurisprudence reste source structurante et façonnante de ce droit. C'est le juge administratif qui crée la norme. Se posent alors des questions notamment de légitimité.

B) Le caractère autonome

On veut signifier ici que le droit administratif est une branche du droit à part entière, distincte du droit privé. Ce caractère est vrai pour le droit administratif français mais pas pour tous les droits administratifs.

Ici, on distingue bien autonome (il se suffit à lui-même) et spécifique (les règles qui en découlent sont différentes du droit commun).

Les deux grands modèles de droit administratif dans le monde:

- Le modèle anglais où l'administration est en principe soumise au droit ordinaire et son contentieux relève des juridictions ordinaires (principe = droit ordinaire sous réserve d'une éventuelle règle dérogatoire de droit administratif). Le droit administratif n'y est donc qu'une simple collection de règles disparates dérogatoires.

=> Ce n'est pas un droit qui peut se suffire à lui-même pour régler un litige.

=> Il n'y a donc ni dualisme juridictionnel ni le dualisme juridique (il n'y a pas de branche de droit autonome face au droit privé).

- Le modèle français où le droit administratif est autosuffisant (lorsqu'il est applicable à un litige, il se suffit à lui-même pour se régler). Il entraîne la compétence d'un ordre de juridiction particulier: la juridiction administrative.

=> Il suffira à régler le litige.

L'opposition a été faite par Dicey dans introduction à l'étude du droit constitutionnel (1885). Il explique que le modèle anglais donne la priorité à l'égalité de tous (y compris l'administration) devant le droit. En face, le modèle français donne la priorité au PRIMA de l'intérêt général: son rôle de défense de l'intérêt général soumet l'administration à un droit inégalitaire et des juridictions spéciales.

=> Il s'agit d'un choix politique.

Tribunal des conflits, 8 Fev. 1873, Blanco: c'est à travers cet arrêt que le choix d'un droit autonome a été fait.

Faits & Procédure: M. Blanco se balade sur les quais de la Garonne à Bordeaux avec sa fille. Les ouvriers d'une manufacture de tabac (alors publiques) renversent une cargaison sur la jambe de la jeune fille qui doit donc être amputée. Il souhaite donc obtenir réparation. Il engage donc son action contre l'Etat en responsabilité devant le juge judiciaire. L'Etat alors adversaire estime lui que le juge compétent est le juge administratif.

Questions de droit:

- Convient-il d'appliquer le droit civil ? Réponds par la négative considérant que le responsabilité qui peut être incomber à l'Etat pour les dommages causés au particulier par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public ne peut être régit par les préjudices qui sont établis par le Code civil pour les rapports de particulier à particulier.
- Qu'applique-t-on alors ? « Que cette responsabilité n'est ni générale ni absolue, qu'elle a ses règles spéciales qui varient suivant les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l'Etat avec les droits privés ». On applique donc un droit spécial qui est alors à l'époque inexistant (cela encourage donc le juge à le créer).

=> Le droit créé est alors (1) autonome (on exclut totalement le droit privé) et (2) jurisprudentiel (le juge du tribunal des conflits encourage le juge administratif à mettre en oeuvre un droit spécial).

=> Il reste alors le principe de la liaison de la compétence et du fond : Le juge judiciaire est compétent pour trancher le litige judiciaire et inversement pour le droit administratif.

Titre I: Les activités administratives

Elles sont principalement au nombre de trois:

- L'activité d'exécution de lois (qui ne sera pas détaillée dans ce cours): celle qui consiste à édicter les règlements d'applications nécessaires pour qu'une loi puisse être concrètement mise en oeuvre.
- L'activité de police administrative: Celle qui vise au maintien de l'ordre public.
- L'activité de service public: Celle qui vise à satisfaire l'intérêt général par la prise en charge d'activités de prestation.

Chapitre 1: La police administrative

Comme la notion d'administration, la notion de police a un double sens:

- Un sens organique: Elle désigne les forces de l'ordre {l'ensemble des personnes chargées d'assurer l'activité de police}.
- Un sens matériel/fonctionnel (qui sera utilisé ici): Elle désigne une activité visant à faire régner l'ordre.

Section 1: La notion de police administrative

§1- Police judiciaire et la police administrative

Ce sont deux activités qui visent à faire régner l'ordre. Elles se distinguent par un critère de distinction jurisprudentiel.

A) LE CRITÈRE JURISPRUDENTIEL DE CETTE DISTINCTION

(1) Le critère finaliste: l'opposition préventif/répressif

La police administrative a une finalité préventive et la police judiciaire a une finalité répressive.

=> La PA cherche donc à prévenir, éviter des troubles à l'ordre public

=> La PJ cherche à donc pour activité la constatation des infractions pénales, en rassembler les preuves et en arrêter si possibles les auteurs afin qu'ils puissent être sanctionnés par un tribunal.

Ce critère finaliste (la fin poursuivie) est jurisprudentiel:

- **CE, section, 11 Mai 1951, Consorts Baud** : Il était ici question d'une activité de police dont l'objet était d'arrêter des individus présentés comme faisant partie d'une bande de malfaiteurs. Ici, il reconnaît le but répressif de la police judiciaire.
- **Tribunal des conflits, 7 Juin 1951, dame Noualek** : Opération qui avait pour objet de prévenir des atteintes à la sécurité publique. Il en déduit qu'il s'agit donc d'une opération de police administrative.
- **Tribunal des conflits, 15 Janv. 1968, Consorts Tayeb**: Le critère finaliste est un critère psychologique: ce que la police pensait faire.
- **CE, assemblée, 24 Juin 1960, Société FRAMPAR**: Le préfet apprend que les journaux s'apprêtent à publier une information qui pourrait être préjudiciable pour l'Etat et fait saisir les journaux. Il fonde sa décision sur un article du Code de l'instruction criminelle (aujourd'hui de procédure pénale) qui lui permet « de faire tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes et délits contre la sûreté de l'Etat ». Ici le préfet cherchait à éviter des troubles à l'ordre public (pour constater l'infraction il aurait simplement pu saisir un seul journal). Il s'agit donc de la police administrative.

L'opposition ici détaillée est parfois contre-intuitive.

(2) Le critère précisé : la question de la prévention des infractions pénales

L'acte ou l'action visant à prévenir une infraction pénale relève-t-il de la police judiciaire ou administrative ?

D'un côté il s'agit d'une opération préventive (police administrative), d'un autre côté, il s'agit d'agir non pas pour l'ordre public mais pour prévenir la commission d'une infraction pénale déterminée (police judiciaire).

En principe, une opération visant à prévenir une infraction pénale déterminée est une opération de police judiciaire. C'est ici l'aspect infraction pénale qui l'emporte.

Ex. Un contrôle d'identité préventif à une possible infraction (exemple de pickpockets soupçonnés) est une opération de police judiciaire.

Ça n'est bien sûr qu'en principe, en effet il existe des cas contraires:

CE, Ordonnance de référé, 9 Janv. 2014, **Ministre de l'intérieur contre société les productions de la plume et M. M'Bala M'Bala** : Il appartient à l'autorité administrative de prendre les mesures qui visent à éviter que des infractions pénales soit commises. (On pourrait croire à un revirement de jurisprudence mais il s'agit plus

CE, 9 Nov. 2015, **AGRIF et société les productions de la plume**: Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public.

Faits et explications: Il y a cependant des cas où des mesures visant à empêcher par prévention la commission d'une infraction pénale, où le but premier est d'éviter un trouble plus général à l'ordre public.

Dieudonné en 2013 à l'occasion d'un spectacle fait des blagues répréhensibles pénalement (négationnistes, incitation publique à la haine sur des individus en raison de leurs appartenances raciales ou religieuses), des maires et/ou préfets prennent des mesures pour empêcher la production de ce spectacle dans certaines villes. Ici, la mesure est considérée de police administrative car les maires agissent avant tout (but premier) pour éviter une atteinte à la dignité humaine (ici trouble à l'ordre public au sens de la police administrative). La police administrative agit ici pour protéger les personnes qui risquent d'être heurtées par les propos.

Arrêt de précision : CE, Ordonnance de référé, 18 Oct. 2023, **Association comité action Palestine** : Le ministre de l'intérieur interdit des manifestations pro Palestine pour éviter le trouble à l'ordre public et la commission d'infractions pénales négationnistes soit commises. « Une mesure d'interdiction qui ne peut être prise qu'en dernière recours peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public en particulier de violences contre les personnes et de dégradations de biens et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de

Tribunal des conflits, 18 Juin 2007, Ousset : Mettre en cellule de dégrisement une personne en état d'ébriété (infraction pénale) constitue une opération de police admin dans la mesure où l'infraction est moindre face au trouble à l'ordre public que pourrait causer ladite personne.

Tribunal des conflits, 5 Dec. 1977, demoiselle Motsch: En cours d'exécution, une opération de police administrative peut changer de nature et devenir une opération de police judiciaire

Ex. Personne tentant de forcer un barrage routier et qui se fait tirer dessus par prévention.

B) LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE LA DISTINCTION

La distinction a principalement une double conséquence juridique.

(1) Les conséquences sur les autorités compétentes pour agir

Les agents d'exécution de ces deux polices sont parfois les mêmes: La police nationale exerce à la fois des missions de police administrative et des opérations de police judiciaire. Idem pour les gendarmes et la police municipale.

En revanche, les autorités responsables (ceux sous lesquels les agents d'exécution agissent) sont radicalement différents:

- La police judiciaire est placée sous la responsabilité de l'autorité judiciaire (exigence de l'**Art. 66 de la Constitution**) du parquet.
- La police administrative est placée sous la responsabilité d'autorités administratives: les maires au niveau communal, les préfets au niveau départemental et le Premier ministre au niveau national. Les maires et les préfets tirent leur autorité de textes (Loi de 1790 pour les préfets, Loi de 1884 pour les maires).
Le Premier ministre en revanche revet sa compétence de **CE, 8 Aout 1919, Labonne** actualisé par **CE, 4 Juin 1975, Sieur Bouvet de la maison neuve**.

- => L'arrêt Labonne portait sur une décision du PdR d'instaurer un système d'autorisation pour avoir le droit de conduire un automobile. On se demande alors si le PdR avait la compétence pour prendre des mesures de police administrative nationale: aucun texte ne lui conférait cette compétence. Ainsi, le CE reconnaît la compétence au niveau national malgré l'absence de texte (interprétation très large de la Constitution de la IIIème).
- => Dans l'arrêt Bouvet de la maison neuve, le Premier ministre impose le port obligatoire de la ceinture de sécurité. Le CE octroie donc sous la Vème le pouvoir de police administrative au niveau national au Premier ministre car dans la Constitution de 1958, le pouvoir réglementaire est reconnu au Premier ministre.
- => Le premier confinement, opération de police administrative au nom de la salubrité publique, bien qu'annoncé par le PdR a bien été signé (sur le décret) par le Premier ministre.
CE, Ordonnance en référé, 22 Mars 2020 : Le Premier ministre peut, en vertu de ses pouvoirs propres, édicter des mesures de polices applicables à l'ensemble du territoire en particulier en cas de circonstances exceptionnelles telles une épidémie avérée comme celle du COVID-19 que connaît actuellement la France.

(2) Les conséquences sur la juridiction compétente

Les litiges relatifs à la police judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire et les litiges relatifs à la police administrative, le litige relève de la juridiction administrative.

Il existe cependant quelques exceptions à ce principe:

- Le droit de la responsabilité:
CASS, 23 Nov. 1956, trésor public contre docteur Giry : Des policiers interviennent suite à la découverte d'un cadavre. Le Dr. Giry apporte son expertise médicale; à son arrivée, a alors lieu une explosion liée au gaz qui le blesse rarement. Le juge judiciaire est ici responsable.
- => Le juge judiciaire saisi d'une action en responsabilité, devrait en théorie (en suivant le principe de liaison de la compétence et du fond consacré par l'arrêt Blanco) appliquer le droit de la responsabilité civile. Sauf qu'il existe une exception au principe: le juge judiciaire doit en réalité appliquer ici le droit administratif.
- => Cette exception existe pour des questions d'équité. En droit administratif, les personnes collaboratrices occasionnelles de l'administration victimes d'un préjudice bénéficient d'un régime (très favorable) de responsabilité administrative sans faute. Il n'existe aucun pareil en droit civil. Ainsi, la Cour consacre ici une équité entre les collaborateurs des deux polices.

Cet arrêt a été récemment confirmé par **tribunal des conflits, 13 Mai 2024, Garde des sceaux, ministre de la justice**

- Les situations où un même préjudice trouve sa cause à la fois dans une opération de police administrative et de police judiciaire:
Tribunal des conflits, 12 Juin 1978, société le profil: L'entreprise a besoin de disposer chaque jour d'une somme en liquide. Ainsi, un de ses salariés va les retirer à la banque. Pour éviter le vol,

celui-ci est escorté. Malgré cette précaution, l'employeur est attaqué et l'argent est dérobé. Ici, la cause est double: défaillance de l'opération de PA (escorte insuffisante...) mais aussi de l'opération de PJ (ils ont échoué à arrêter les malfaiteurs).

Le tribunal décide qu'une unique juridiction est compétente afin de faciliter l'action: celle qui regarde la police dont les défaillances sont essentiellement la cause du préjudice.

§2- La distinction entre la police administrative générale et les polices administratives spéciales

Une différence fondamentale: les polices administratives spéciales sont toujours régies par des textes particuliers (ça n'est que partiellement distinctif, des polices administratives générales dépendent de textes (maires, ...)). Au delà du fondement textuel, les PA spéciales ont un champ d'application forcément plus réduit que la PA générale. Il existe ensuite d'autres éléments distinctifs mais qui ne sont pas applicables à toutes les PA spéciales.

(1) L'élément systématiquement distinctif

L'élément systématiquement distinctif est le champ d'application. La PA générale est susceptible de s'appliquer à toute personne, en tout temps et en tout lieu. En revanche, les PA spéciales ont elles un champ d'application restreint: certaines personnes (PA des étrangers), certaines activités (PA de la pêche et de la chasse), certains lieux (gares), certaines situations (état d'urgence)...

(2) Les éléments variables de distinction

- Les autorités compétentes : la PA peuvent appartenir aux maires, préfets, Premier ministre mais ça n'est pas nécessairement le cas des PA spéciales (ex. La police de l'université, sous l'autorité du président de l'université en vertu du Code de l'éducationnel).

=> **CE, 18 Oct. 2023, Association comité action Palestine**: Le ministre de l'intérieur n'a pas de pouvoir au titre de la police administrative spéciale des manifestations. Cependant, en l'espèce, le CE ne condamne pas Gérald Darmanin car son télégramme n'était pas une décision d'interdiction mais qu'une demande aux préfets.

- Les buts poursuivis : Le but de la PA spéciale est toujours de protéger l'ordre public. Cependant, la notion d'ordre public diffère pour certaines PA spéciales: les 4 éléments pour la générale (la sécurité, la tranquillité, la salubrité, le respect de la dignité de la personne) contre d'autres pour certaines.

=> Exemples:

Police de l'affichage, de la publicité et des enseignes (détenue par le maire) dont les certains buts sont différents (l'esthétisme public, nb, elle ne fait pas partie de l'ordre public de manière générale mais peut en être une composante spéciale (**CE, 21 Juil. 1970, Loubat**)).

Police de l'eau qui peut agir aux termes de la protection de l'environnement.

- Les procédures d'éviction et d'exécution: Une procédure assez souple (simplement motiver sa décision) s'appliquent à la PA générale mais certaines PA spéciales ont des procédures d'éviction des actes spéciales ou d'exécutions spéciale.

=> Ex (éviction): PA spéciale des édifices en ruines où le maire doit suivre une procédure contradictoire avant de prendre un arrêté.

=> Ex (exécution): PA spéciale d'état d'urgence sanitaire dont la loi dispose (CSP) que les actions peuvent être exécutées d'office (par la force) + augmentation du niveau des contraventions.

Section 2: Le régime juridique de la police administrative

§1- La compétence de la police administrative

A) LES AUTORITÉS DE POLICE ADMINISTRATIVE ONT ELLES L'OBLIGATION OU FACULTÉ D'AGIR ?

Dans la plupart des cas, les autorités de police administratives ne sont pas libres d'agir ou non. Si on peut parler d'une obligation d'agir c'est par ce qu'une éventuelle carence dans l'exercice des pouvoirs de police administrative est susceptible d'être sanctionnée (au sens large).

Cette sanction peut prendre la forme de:

- Une condamnation à verser des dommages et intérêts lorsqu'elle a causé un préjudice à des administrés

CE, 9 Nov. 2018, Association la vie Dejean : Les habitants d'un quartier parisien particulièrement touché par des problèmes de drogue ect. Demande à la PA compétente d'agir et ceux-ci ne font rien. Les habitants démontrent qu'une faute leur a causé un préjudice et demande indemnisation. Le juge a condamné l'administration à verser des dommages et intérêts.

- Une annulation de la décision de l'autorité compétente soit de ne pas agir soit agir de manière insuffisante. Ici, la carence est une illégalité qui relève du contentieux de l'excès de pouvoir. En pratique, l'annulation est plus efficace.

=> Arrêt de principe: **CE, 23 Oct. 1959, Doublet**: Dans une commune, un camping privé cause des nuisances aux riverains. Le maire refuse (par décision ou tacitement) de prendre une décision pour y mettre fin après une requête de M. Doublet. Le CE lui donne gain de cause et annule la décision de refus.

La jurisprudence limite dans la décision cette possibilité à la situation où les autorités de polices sont soumises à un péril grave résultant d'une situation dangereuses pour l'ordre public.

Celle-ci a par la suite été utilisée avec succès par des ONG. Le CE admet donc que cette JP peut être utilisée lorsque la nature de la carence porte atteinte à la dignité humaine en exposant des personnes à des traitements inhumains et dégradants.

Illustrations :

CE, Ordonnance, 23 Nov. 2015, Association médecins du monde : De nombreux migrants bloqués à Calais dans le but d'aller au RU et vivent dans des espèces de bidonvilles. Médecins du monde saisit donc le CE en engageant une action en recours au référendum de liberté (atteinte grave et manifestes par l'administration aux libertés fondamentales) qui donne des moyens élargis au juge (annulation + ordonner toute mesure utile pour régler la carence).

En pratique, les juridictions administrative ont aujourd'hui une tendance à faire interprétation de doublet dans beaucoup de cas (ex. **TA Marseille, 3 Aout 2020** qui force la PA à interdire des rodéos urbains).

B) L'INTERDICTION DE DÉLÉGUER

Il est possible pour une personne publique responsable d'un service public d'en déléguer la gestion à un tiers. En revanche, l'activité de PA ne se délègue pas.

Cela résulte de **CA, assemblée, 17 Juin 1932, ville de Castelnaudary**: Les maires sont chargés d'une PA spéciale, la police rurale dont est chargé le garde champêtre. Le maire décide alors de déléguer cette mission aux chasseurs de la commune. « Considérant que le service de police rurale, par sa nature, ne saurait être confié qu'à des agents placés sous l'autorité directe de l'administration. Qu'en confiant la charge de ce service à une fédération de propriétaires privés, le conseil municipal de Castelnaudary a excédé ses pouvoirs ».

Exemple plus récent: **CE, 29 Dec. 1997, commune d'Ostricourt** : Le maire confie la mission de surveillance des voies publiques à une société privée (vigiles).

Cette interdiction résulte de la JP mais également de la Constitution elle-même désormais (JP du C; constit. Depuis une vingtaine d'années). En effet, **C. Constit, QPC, 15 Oct. 2021, Société Airfrance**: le Conseil a estimé que l'interdiction de déléguer la PA était plus qu'un simple principe constitutionnel mais un « principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France ».

Ce grand principe connaît également des exceptions (ou au moins des assouplissements). Certaines choses en lien avec la PA peuvent être déléguées. Ce qui ne se délègue pas, c'est la compétence pour prendre les décisions, les tâches matérielles indissociables de la PA. Ce qui peut être délégué, ce sont les tâches matérielles dissociables de la PA.

C) DÉTERMINATION DE LA POLICE ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE

Dans une même situation, un même risque à l'ordre public, il est possible que plusieurs polices soient compétentes (PAG qui dépendent du maire ou du préfet comme PAG et PAS).

(1) La répartition des compétences

Entre les différentes autorités de police administrative générales, le maire est compétent lorsqu'il s'agit de lutter contre une menace pour l'ordre public limitée au territoire d'une commune, le préfet pour une menace qui regarde le territoire départemental et le Premier ministre lorsque la menace regarde le cadre régional.

En réalité, les choses sont plus complexes pour plusieurs raisons:

- Le cas particulier où n'importe quelle autorité de PAG a vocation pour intervenir: lorsqu'il faut prendre des mesures destinées à protéger la dignité de la personne humaine (Ex. **CE, assemblée, Morsang-sur-orge, 27 Oct. 1995** où le maire avait interdit les lancers de nain sur le territoire de sa commune, le CE consacre alors la capacité du maire à interdire la pratique sur sa commune alors même que la menace était de niveau national au niveau de la dignité humaine).
- L'exercice de sa compétence par une autorité de PAG n'exclut pas nécessairement qu'une autre autorité de PAG intervienne: une autorité de PA a la compétence pour aggraver les mesures prises par une PA supérieure dès lors qu'existe des circonstances locales particulières (**CE, 18 Avril 1902, commune de Nérès-les-bains** et **CE, 8 août 1919, Labonne**).
- Les préfets peuvent se substituer aux maires après mise en demeure restée infructueuse, en cas de carence de ceux-ci dans l'exercice de leurs pouvoirs de police administrative (**Art. L2215-1 Code général des collectivités territoriales**).
- Dans certaines communes (qui sont en réalité nombreuses), une partie des pouvoirs de PAG ne sont pas exercés par les maires mais par les préfets.

=> Communes où la police est dite étatisée: chefs lieux de départements + une liste fixée (en fonction du nombre d'habitants, du taux de délinquance, de communes touristiques).

Ex. troubles à la tranquillité publique (sauf les troubles de voisinage).

⚠ Exception pour Paris où le préfet de police est en principe compétent au titre de la PAG et le maire ne sera compétent que par exception (ex. Salubrité des voies publiques, grèves des éboueurs, bruits de voisinage...).

(2) Les concours de police

Ici, soit plusieurs PAS se déclarent compétentes, soit à la fois la PAG et la PAS se disent compétentes.

Le cas de concours entre polices spéciales: Le principe qui s'applique c'est l'**indépendance des législations**. Cela veut dire que lorsque deux PAS ont vocation à intervenir, les deux doivent intervenir.

Ex. Un propriétaire privé a planté un bois à proximité d'un monument historique et décide de raser celui-ci. Ici, la PAS des forêts (ministre de l'agriculture) et la PAS des monuments historique

(ministre de la culture) étaient compétentes (protection de l'environnement et cadre du monument historique). Ici, le propriétaire devait demander deux autorisations aux deux PAS.

Le cas du concours entre PAG et PAS: En principe, c'est l'autorité de PAS qui a capacité pour agir au détriment de la PAG.

Il existe des nuances:

Les cas d'exclusion totale	Les cas d'exclusion quasi-absolue	Exception
<i>C'est l'exclusion sans exception</i>	<i>Il y a une petite fenêtre d'intervention</i>	
Ce sont les cas où se posent des questions techniques (au sens scientifique): une expertise est nécessaire	Cas où l'existence d'une PAS exclut l'intervention de la PAG sauf en cas d'urgence constituée d'un péril grave et imminent	Cas où des circonstances locales particulières justifient que soient prises des mesures plus sévères
Exemples: - CE 26 Oct. 2011, Commune de Saint Denis: Le maire n'a pas le pouvoir d'interdire l'installation d'antennes relai près de lieux car il existe une PAS des antennes relai. - CE 24 Sept. 2012, Commune de Valences: La culture d'organismes génétiquement modifiés ne peut être interdit par un maire dans la mesure où il existe une PAS des OGM.	Exemples: - Il existe une PAS des installations classées (dangereuses commune une usine) cependant, l'explosion d'une usine par exemple justifie l'action du maire - CE, 15 Janv. 1986, Société PEC engineering	Exemple: - CE, section, 18 Dec. 1959, Société les films lutetia : Malgré le visa d'exploitation délivré par le ministre de la culture obtenu, un maire d'une commune estime qu'il ne serait pas acceptable que le film soit diffusé dans sa commune dans la mesure où il y a une scène un peu érotique. - CE, 17 Avril 2020, Commune de Sceaux: Un maire peut prendre des mesures plus importantes vis à vis de l'état d'urgence sanitaire, ici pour un quartier concentrant plus de personnes âgées à condition que la mesure ne compromette pas la cohérence et l'efficacité des mesures prises par la PAS. Nb. Cette exception a très rarement été admise.

§2- Les composantes de l'ordre public général

Le but de la PA est la protection de l'ordre public. Cependant, cette notion est polysémique: elle n'a pas la même notion selon les branches du droit.

En droit administratif, l'ordre public est celui susceptible de fonder des restrictions aux libertés de la part des autorités de PA. Il n'a pas toujours le même sens selon que l'on parle de la PAG ou une PAS. En effet, certaines PAS disposent de composantes supplémentaires dans leur notion d'ordre public. Nous allons donc étudier l'ordre public au sens de la PAG.

A) LES COMPOSANTES TRADITIONNELLES DE L'ORDRE PUBLIC: L'ORDRE PUBLIC MATÉRIEL

Il y a trois composantes à cet ordre public. Celles-ci permettent aux services de PA de lutter contre des désordres matériels (nuisances, épidémies, blessés ect.).

(1) La salubrité publique

C'est les cas où il s'agit de lutter contre les risques sanitaires notamment en veillant à la salubrité de l'eau, à l'hygiène des denrées alimentaires ou encore à la propreté des rues.

(2) La tranquillité publique

= Lorsqu'il s'agit de protéger des troubles excessifs de la vie en société allant des nuisances sonores aux attroupements.

(3) La sécurité publique

Cela consiste à agir pour protéger essentiellement l'intégrité physique des individus et éventuellement les biens. Pendant longtemps, il s'agissait de protéger les uns contre les autres (tiers contre autrui).

Or, depuis une évolution jurisprudentielle, on admet que la PAG puisse agir au nom de la sécurité publique afin de protéger les individus contre eux mêmes: **CE, 4 Juin 1975, Sieur Bouvet de la maison neuve** (ici imposition du port de la ceinture de sécurité).

Cette évolution est aussi importante d'un point de vue philosophique: la conception de la liberté que l'on se fait.

Liberté individuelle au sens de la DDHC: « c'est la liberté de faire toute ce qui ne nuit pas à autrui ». Or, avec cette JP, les autorités de PA peuvent porter atteinte aux libertés quand bien même ils ne nuiraient pas à autrui.

B) LA COMPOSANTE DISCUTÉE: L'ORDRE PUBLIC IMMATÉRIEL

On admet depuis toujours que la PA puisse prévenir des désordres matériels. Hauriou disait « L'ordre public, au sens de la police, est l'ordre matériel et extérieur considéré comme un État de fait opposé au désordre ». Selon lui, la PA n'est pas faite pour lutter contre les désordres moraux.

Cependant, le droit positif français et la jurisprudence administrative ne correspondent pas exactement l'analyse d'Hauriou:

- D'une part, le CE n'a jamais consacré dans un arrêt de principe la moralité publique comme une composante de l'ordre public.
- Cependant, le CE a consacré une partie de cette moralité publique comme composante de l'ordre public: **la dignité humaine**. Les autorités peuvent donc agir pour prévenir des troubles dans les consciences causés par une action portant atteinte dans la morale de chacun à la dignité de la personne humaine.

Dans la logique, il s'agit tout de même d'une consécration de l'ordre public immatériel.

En creusant dans la jurisprudence, on se rend compte qu'il existe tout de même un certain nombre d'arrêts du CE qui valident des arrêtés de police sanctionnant une atteinte à la moralité publique.

(1) La consécration du respect de la dignité de la personne humaine

Cette quatrième composante de l'ordre public a fait l'objet d'une consécration par un arrêt de principe : **CE, assemblée, 27 Oct. 1995, Morsang-sur-orge**. Dans cet arrêt, le CE affirme expressément que l'ordre public au sens de la PAG comporte désormais une quatrième composante immatérielle: le respect de la dignité de la personne humaine.

=> Ici, le maire n'agissait ni au nom de la sécurité publique, ni de la salubrité publique, ni de la tranquillité publique.

Rétroactivement, cette composante a conféré un fondement juridique à l'arrêté du maire.

La protection du respect de la dignité de la personne humaine est une composante de l'ordre public qui se suffit à elle-même.

Cet aspect ressort encore plus clairement de [CE, 9 Nov. 2015, AGRIF](#): « Considérant, en troisième lieu, que des propos et gestes, notamment ceux à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde Guerre Mondiale, peuvent porter atteinte à la dignité de la personne humaine, alors même qu'ils ne provoqueraient pas de troubles matériels ».

=> Une partie de la moralité publique permet donc aux autorités de PA de limiter les libertés.

Attenter le statut de la dignité humaine, revient à ramener l'être humain au statut de chose (un nain, un juif...).

Cet arrêt (27 Octobre) n'a en pratique que des effets limités: il est - heureusement- rare que les autorités de PA aient à limiter la liberté au nom de la dignité humaine. En vingt-neuf ans, le CE n'a appliqué Morsang-sur-orge que quelques fois ce qui n'a donc pas considérablement étendu les pouvoirs de la PA.

Décisions d'application:

- L'arrêt de principe, affaire Dieudonné;
- [CE, 5 Janvier 2007, Association solidarité des français](#) : association proposant aux sdf de la soupe contenant du porc et le préfet de police de paris prend un arrêté interdisant cette distribution discriminatoire de soupe
- [CE, 4 Mars 2023, Madame C.](#), arrêté du maire qui interdit une conférence dans laquelle devaient intervenir des imams salafistes dont un ayant tenu des propos inappropriés à l'encontre des femmes ou encore des attentats du bataclan
- [CE, 16 Fev. 2024, Freeze Corleone](#): rappeur connu pour des provocations récurrentes notamment antisémites, le maire de Lyon interdit le concert

⚠ Il ne faut pas confondre atteinte à la dignité humaine avec des propos/actes choquants.

Ex. [CE, 16 Avril 2015, Société Grasse boulange](#) : Ce pâtissier a pour spécialité des pâtisseries représentant l'iconographie colonialiste. Celles-ci sont exposées en vitrine et choquent certains passants. Le maire ne prend pas d'arrêté alors qu'on le lui demande (l'usage des pouvoirs de PA étant une obligation). Le CE a considéré qu'elles n'étaient pas suffisamment choquantes pour constituer une atteinte à la dignité de la personne humaine.

Il advient alors de se demander si la jurisprudence Morsang-sur-orge a été étendue. La première ordonnance (9 Janv. 2014) rendue dans l'affaire Dieudonné y avait laissé penser : « de graves atteintes au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par la tradition républicaine »

=> Les autorités de PAG auraient donc pu agir pour prévenir n'importe quelle atteinte à la moralité républicaine (laquelle inclut la dignité de la personne humaine mais va bien au delà).

Cette rédaction était sûrement une erreur de plume ou une parenthèse rapidement fermée derrière avec [CE, Ordonnance, 26 Août 2016, ligue des droits de l'homme](#): N'est pas valide l'arrêté qui interdit le port du burkini à la suite des attentats de Nice, le maire prétendant ici agir au nom de la laïcité (part de la morale républicaine).

(2) L'absence d'exclusion absolue de la moralité publique

Il n'y a aucun arrêt de principe consacrant la moralité publique comme composante de l'ordre public au sens de la PAG. S'il n'y a pas d'arrêt de principe la consacrant, il n'y a pas non plus d'arrêt de principe l'excluant.

Il existe donc des décisions d'espèce qui au moins implicitement ont reconnu la légalité de mesures de police qui ne pourraient s'expliquer que par la protection de la moralité publique

Quelques exemples:

- [CE, 30 Mai 1930, Beaugé](#): Est légal l'arrêté de police réglementant les tenues de bain sur les plages de sa commune (alors qu'il n'y a aucun fondement de PAG le permettant).
- [CE, 8 Juin 2005, commune de Houilles](#): Est légal l'arrêt visant à interdire l'ouverture d'un sex-shop à proximité d'un établissement scolaire, le but ici étant de protéger la moralité de la jeunesse.
- [TA de Bordeaux, 2021](#): Est légal l'arrêté interdisant à des manifestants de manifester nu.

Focus sur un arrêt: **CE, section, 18 Décembre 1959, Société des films lutetia** :

Le CE a donné raison au maire en question en considérant qu'un maire peut, dans sa commune, sur les fondements de ses pouvoirs de PAG, interdire un film en raison de circonstances locales particulières si ce film apparaissait comme immoral.

Le prof. Maisonneuve ne considère pas cet arrêt comme consacrant la moralité publique comme composante de l'ordre public car il ne faudrait pas donner à cet arrêt une portée qu'il n'a pas : peut-elle réellement s'appliquer à d'autres situations ?

Deux éléments:

- On est déjà ici dans un cas particulier (concours de police entre PAG et PAS)
- En soixante-cinq ans, l'arrêt n'a fait l'objet que d'une seule application négative, **CE, 8 Dec. 1997, commune d'Arcueil** : le maire avait interdit des affiches promouvant les messageries roses, le CE rappelle la JP société des films lutecia pour estimer qu'ici les conditions ne sont pas réunies (pas de circonstance locales en l'espèce qui justifieraient l'interdiction).

Il y a donc eu une seule forme immatérielle de l'ordre public de consacrée (La dignité de la personne humaine). En principe, les autorités de PA ne peuvent donc en principe pas aller au delà mais ce propos peuvent faire objet de nuances: il y a tolérance du juge dans des cas particuliers rares + société des films lutecia.

Section 3: Le contrôle juridictionnel des mesures de police administrative

Le contrôle qu'exerce le juge est particulier et différent de celui qu'il porte normalement sur les actes administratifs car les actes de PA sont attentatoires aux libertés.

Sont interdites par nature certaines opérations de PA qui ne disposent pas de fondement législatif: Celles par lesquelles l'autorité de police compétente instaure un régime d'autorisation préalable **CE, Assemblée, 22 Juin 1951, Daudignac**: Est illégal l'arrêt qui instaure un régime d'autorisation préalable à la profession de photographe-filmer dans les rues d'une commune (le type de mesure prise est en tout état de cause illégal).

En revanche, pour les chauffeurs taxis par exemple, la loi peut prévoir un tel régime.

Le juge administratif cherche à exercer une juste conciliation entre d'un côté la protection de l'ordre public et d'un autre la protection des libertés auxquelles la mesure de police porte atteinte: ordre vs. Liberté.

 Une mesure de police n'est pas illégale par ce qu'elle porte atteinte à telle ou telle liberté. Par définition elle y porte atteinte. Ainsi, la question est de savoir si elle ne sont pas exagérément restrictives de liberté (y a-t-il juste conciliation entre l'ordre et la liberté ?).

Le juge vérifie (1) si l'autorité qui a pris la mesure était bien compétente, (2) si elle a agi pour atteindre un but qu'elle pouvait poursuivre (composantes de l'ordre public), (3) si le risque de trouble à l'ordre public est réel et (4) si la mesure ne porte pas excessivement atteinte à telle ou telle liberté.

Sur la question de la conciliation, le juge doit porter un contrôle renforcé.

« La liberté est la règle et la restriction de police l'exception » Louis Corneille, Commissaire du gouvernement (ancien Rapporteur public) sur l'affaire Baldy (CE, 10 Août 1917)

Autrement dit, dans une démocratie libérale, les atteintes aux libertés résultant de mesures de PA doivent être exceptionnelles ce qui justifie le contrôle maximum du juge.

Ce contrôle maximum et les règles sur son opération sont posées par un arrêt de principe: **CE, 19 Mai 1933, Benjamin**; Sont illégaux les arrêtés interdisant les réunions politiques- dans un lieu public (1er arrêté) comme privé (2ème arrêté)- de M. Benjamin à Nevers.

Le juge pose dans un premier temps le principe puis la nécessité d'une conciliation étroite entre ordre public et liberté. : « Considérant que, s'il incombe au maire (...), de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre, il doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté ».

⚠ Le contrôle maximum (dit maximum) n'est pas particulier de par le fait qu'il soit un contrôle de proportionnalité : l'intensité du contrôle exercé sur les actes est variable, parfois maximum donc un contrôle important. Il arrive que le juge exerce un contrôle de proportionnalité dans le cadre d'un contrôle restreint ou non. C'est ici un contrôle de proportionnalité plus exigeant que celui exercé dans un contrôle restreint ou normal.

Le contrôle maximum se distingue par le fait que le contrôle de proportionnalité est plus exigeant de par sa non limite à l'examen de la proportionnalité intrinsèque: il s'étend à l'examen de la proportionnalité extrinsèque. On va vérifier qu'il n'y aurait pas une autre mesure encore mieux proportionnée (qui réponds au même but mais en atteignant moins les libertés).

Ce contrôle extrinsèque est un contrôle réaliste de la proportionnalité: la mesure alternative doit être réalisable.

Ainsi, plus une mesure de PA est générale et absolue, plus il ya de chances qu'elle soit disproportionnée et plus il y a de chances qu'elle soit illégale.

Ex. **CE, 11 Juin 2012, Commune de l'étang salé**: Est illégal l'arrêté de police interdisant les voitures de propagande électorales munies d'un haut parleur. (Ici les voitures auraient pu être autorisées à circuler la journée en semaine).

Contre-exemple: Morsang-sur-orge.

Dans le dernier état de sa jurisprudence, le CE a quelques peut précisé la méthode à mettre en oeuvre pour s'assurer que le contrôle soit maximal (précision de la JP Benjamin) que l'on retrouve systématiquement depuis l'ordonnance du 9 Janvier 2014, le contrôle doit être:

- Nécessaire : Il faut agir nécessairement.
- Adapté : Cela signifie que la mesure prise doit être pertinente pour prévenir le trouble à l'ordre public
- Proportionné : La mesure prise ne doit pas porter une atteinte excessive aux libertés (dans le cadre d'un contrôle maximum = pas de mesures alternatives mieux proportionnées possibles).

La question de la juste conciliation s'apprécie donc IN CONCRETO (nombre de manifestants, type d'organisateur d'un événement, lieu ect.).

Il advient donc de se demander si ce contrôle maximum a également lieu pour les PAS. Cela dépend mais la tendance consiste à soumettre (pas toutes) les mesures de PAS au même contrôle maximum que les mesures de PAG.

Ex. **CE, 11 Dec. 2015, Domenjoud** : Les mesures de police prises au titre de l'état d'urgence sécuritaire sont soumises à un contrôle maximum.

Il en va de même pour la PAS du cinéma, état d'urgence sanitaire, des supporters, des manifestants.

Chapitre 2: Le service public

C'est une notion politiquement chargée tant positivement que négativement.

Léon Duguy et ses disciples (école du service public) avaient tenté de faire du service public le critère du droit administratif (v. Supra). Gaston Gèze, un des disciples disait que « le service public est la pierre angulaire du droit administratif ». Cette idée ne correspond plus à l'état du droit positif (service public $\neq$ droit administratif).

Il reste cependant l'une des principales activités de l'administration.

Section 1: la notion de service public

Pr. D. Truchet considère le service public comme « une activité prioritairement d'intérêt général maîtrisée par une personne publique ».

Pr. R. Chapus disait lui que le service public « c'est une activité d'intérêt général assurée et assumée par une personne publique » (RDP, service public et puissance publique)

Outre l'intérêt général et la personne publique, l'objet de cette activité est toujours ou presque de fournir des prestations qu'elles soient matérielles (eau, électricité) ou intellectuelle (enseignement, culture).

§1- L'identification du service public

Dans certains cas, la question est simple: il existe des qualifications textuelles (lois, parfois des décrets).

Ex. Code de l'éducation qualifie l'enseignement supérieur de service public, pompes funèbres assurées par une commune ect.

=> ⚠ A bien lire: les pompes funèbres assurées par une commune sont un service public, elles peuvent être libérales également.

Pour les autres cas, il y a deux critères dont il faut vérifier qu'ils sont remplis (cumulatifs):

- Le critère finaliste: la finalité de l'activité en question doit être d'intérêt général
- Le critère organique: il faut que l'activité soit en lien avec une personne publique.

A) LE CRITÈRE FINALISTE DE LA NOTION DE SERVICE PUBLIC

But = **intérêt général**.

Il faut alors se demander ce qu'est l'intérêt général. Cependant, l'intérêt général est une notion fixe à contenu variable : elle désigne la même chose avec une précision variable dans le temps et dans l'espace (Les besoins collectifs d'hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui).

Ex. L'activité théâtrale posait débat il y a un temps et la question se posait au contentieux. Ex. **CE, 7 Avril 1916, Astruc**. Pour Hauriou comme beaucoup, il était évident que l'activité théâtrale n'était pas d'intérêt général (il la considérait comme mauvaise).

Ou encore les casinos eux développent l'intérêt culturel, touristique et de développement économique de la commune (**CE, 19 Mars 2012, groupe partouche**).

Aujourd'hui, il n'y a plus d'activité que l'on ne peut plus considérer comme d'intérêt général.

Ex. Organiser un lâcher de taureau, organiser un évènement sportif, tirer un feu d'artifice pour le 14/07, gérer un cinéma, gérer un restaurant

Le spectre des activités regardées comme d'intérêt général est large.

Pour autant, ça n'est pas le juge qui a imposé cette vision large de l'intérêt général. Le juge considère que ça n'est pas à lui mais aux pouvoirs publics de définir ce dernier. Dès lors, il considère qu'**une activité prise en charge par une personne publique est présumée être d'intérêt général**. Si les pouvoirs publics décident de s'intéresser à telle ou telle activité, c'est que ceux-ci la considère utile aux besoins de la population.

Par conséquent, ce critère finaliste est très second, accessoire. Le critère principal est donc le critère organique car le critère finaliste est rempli par présomption.

Il existe deux exceptions (chute de la présomption):

- **CE, section, 27 Oct. 1999, Rolin** : L'activité de la française des jeux, malgré le critère organique rempli, n'est pas un service public.
- => La française des jeux a longtemps été une entreprise publique (société privée dont l'actionnaire majoritaire est l'Etat).
- **Tribunal des conflits, 18 Juin 2001, Laidier c. Ville de Strasbourg** : La gestion par la personne publique de son domaine privé {un des deux régimes de la propriété publique} notamment son domaine forestier n'est pas d'intérêt général quand le lien entre l'activité exercée et l'intérêt général est trop indirect.

Nb. Domaine public = a usage public (rue ect.) ou affecté à un service public.

B) LE CRITÈRE ORGANIQUE

C'est le critère essentiel du service public.

Ex. La croix rouge satisfait l'intérêt général mais est totalement indépendante des services publics. Idem pour les partis politiques qui sont juridiquement indépendants des pouvoirs politiques (CASS, 25 Janv. 2017, Front National).

Il faut que l'activité soit **maitrisée** par une personne publique (et pas exercée). La maitrise passe par le fait de simplement assumer sans assurer l'activité; il est fréquent que des activités de service public que soient pas assurées par les personnes publiques mais des personnes privées (ex. Enlèvement des ordures ménagères qui est souvent délégué). Le lien organique peut donc être satisfait même lorsque la personne publique ne s'occupe pas de la gestion de l'activité.

Le fait que des activités de services publics puissent être gérées par des personnes privées posent un problème quant à l'identification du service public: comment savoir que la personne publique maitrise et assume le service ?

Le juge administratif a dégagé une **méthode jurisprudentielle** servant à régler cette question.

Celle-ci résulte de deux arrêts:

CE, 28 Juin 1963, Nancy: Le juge considère ici qu'une activité gérée par une personne privée est un service public lorsque cette personne privée assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et lorsque cette personne est dotée pour les besoins de cette mission de prérogatives de puissance publique.

=> Si une personne publique s'intéresse tellement à une activité au point de doter d'une de ses compétences la personne privée qui l'exerce alors le lien organique est fondée.

=> Si pas de prérogatives publiques, pas d'application de Nancy (conditions cumulatives)

CE, 22 Fev. 2007, APREI: Il ne constitue pas un revirement de jurisprudence par rapport à Nancy, il vient le confirmer.

- 1) Y-a-t-il un texte ? (Nommant ou refusant de nommer service public)
- 2) Nancy
- 3) Si pas de prérogatives de puissances publiques, compensation possible par plusieurs éléments (indices) qui peuvent permettre de dégager le service public (Méthode du faisceau d'indices).

Applications de APREI:

CE, 5 Oct. 2007, Société UGC-ciné-cité

=> L'indices en l'espèce:

Une société d'économie mixte (capitaux de la société à la fois privés et publics avec pour actionnaire majoritaire en l'espèce la commune).

La ville n'impose pas d'obligations à la sociétés (tarifaires, programmation).

Pas d'objectifs fixés.

=> On a donc un indice de lien et des indices en sens contraires. Le juge met en balance les indices et ressorts que le lien organique n'est pas suffisamment fort.

CE, 15 Fev. 2016, Société cathédrale d'images:

=> Indices en l'espèce

Les spectacles ont lieu dans les carrières de lumière, propriété de la ville (la commune loue les lieux)

La commune percevait une partie des recettes de billetterie

La ville n'intervenait nullement dans la programmation ou la fixation des tarifs

=> Ça n'est pas un service public

CE, 9 Dec. 2016, commune de Fontvieille

CE, section, 6 Avril 2007, commune d'Aix-en-Provence : La ville subventionne le festival d'art lyrique et demande en échange un droit de regard (activité privée qui s'est transformée en activité de service public de part l'intérêt progressif de la commune.

La notion de service public n'est pas objective mais subjective car elle dépend moins de ce qui est que de ce que veulent les pouvoirs publics. Elle dépend principalement de l'intentionnée de la volonté des pouvoirs publics.

=> Le juge cherche donc à connaître l'intention des pouvoirs publics. A défaut de volonté expresse des pouvoirs publics (loi), on cherche la volonté implicite de la personne publique: si la personne publique prend en charge c'est qu'elle la considère service public, si elle est exercée par une personne privée, application de Narcy et APREI.

Pr. Truchet « le service public est moins une notion qu'un label ».

§2- La distinction des Services Publics Administratifs et des Services Publics Industriels et Commerciaux

Au sein de la catégorie des services publics, il existe deux sous catégories. Le régime juridique applicable est variable en fonction.

Cette distinction est née de Tribunal des conflits, 22 Janv. 1921, société commerciale de l'ouest africain : le tribunal distingue deux catégories de services publics, les SPA (soumis au droit administratif et au juge administratif) et les SPIC (relèvent du droit privé et du juge judiciaire en principe), en l'espèce, il distingue un SPIC.

A) LES CRITÈRES DE DISTINCTION

Deux remarques préliminaires sur ces critères:

- Ces critères sont supplétifs: ils ne sont appelés à jouer qu'en l'absence de source textuelle.

Ex. Service public des remontées mécaniques et de l'exploitation des pistes de ski est consacré par le Code du tourisme comme SPIC.

- Ces trois critères sont cumulatifs: s'il en manque un, il est un SPA et pas un SPIC. Ainsi, **le service public est présumé être un SPA.**

Ces trois critères ont été dégagés dans CE, 16 Nov. 1956, Union syndicale des industries aéronautiques.

L'objet du service: S'agit-il d'une activité à laquelle une entreprise privée pourrait spontanément se livrer ? Si oui SPIC, si non SPA.

Ex. Une activité qui par nature ne serait pas rentable est un SPA (aides sociales).

Autoroutes = activité en lien avec la souveraineté (axes de circulation nécessaires au commerce); ainsi il faut nécessairement que l'Etat vous sollicite (tribunal des conflits, 20 Nov. 2006, société ECTL)

Les ressources du service: Le service est-il financé comme pourrait l'être une entreprise ordinaire ? Oui = SPIC sinon SPA.

=> Une même activité peut parfois être un SPIC et parfois un SPA en fonction de comment elle est financée.

Ex. Ordures ménagères qui sont financées soit par une taxe d'enlèvement des ordures ménagères (SPA) soit par une redevance versée par les usagers; plus on jette, plus on paie cher (SPIC) (tribunal des conflits, 28 Mai 1979, syndicat d'aménagement de Cergy-contoise (SPA), CE, 10 Avril 1992, société Hoffremiller (SPIC)).

Les modalités de fonctionnement du service: Le service fonctionne-t-il comme une entreprise privée ?

=> Chercher des clients ou attendre qu'il vienne, comptabilité publique ou privée, fonctionnaires ou contractuels

Ex. **Tribunal des conflits, 9 Janv. 2017, société centre Léman**, L'exploitation d'un centre aquatique, en l'espèce service public, est, au vu du fait que le centre soit géré par une inter-communalité, des fonctionnaires y sont affectés et le budget se confond avec celui de la communauté, il manque UN critère. L'activité est donc un SPA.

B) LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES DE LA DISTINCTION

Les usagers	
SPA	SPIC
• Régime de <u>droit public</u> • <u>Juge administratif</u> • <u>Situation statutaire</u>; des actes unilatéraux déterminent leurs droits et obligation (pas de choix, pas de contrat...) Nb. Les pseudos contrats signés ne sont pas des contrats (ex. Charte) car ils ne changent pas la situation juridique de l'usager Rappelé par CE, 5 Juillet 2017, Mme B <u>Exception</u>: locataires de logements sociaux gérés par un office public d'HLM ont conclu un bail d'habitation, les droits et obligations découlent donc bien d'un contrat. => Situation contractuelle de droit privé	• Régime de <u>droit privé</u> • <u>Juge judiciaire</u> • <u>Situation contractuelle</u> => Les usagers des SPICS passent un contrat avec. Tribunal des conflits, 24 Juin 1954, Galland: Arrêt de principe. Principe fort: <u>pas d'exception + principe attractif</u> (prime sur des principes contraires). Sur le principe attractif: Bateau prend feu dans un port de plaisance (SPIC), opposition du principe au principe d'usage de l'ouvrage public (le port). On a donc un double statut: usage du SPIC (juge judiciaire) et usage de l'ouvrage public (juge administratif). Le principe Galland l'emporte. Le principe d'applique aux usagers des SPIC mais aussi des candidats à l'usage des spics et des usagers en situation irrégulière. => Tribunal des conflits, 5 Deg. 1983, Niddam c. SNCF (a fraudé). => CE, 21 Avril 1961, Dame Agnesi (Demande refusée de raccordement à l'eau potable, on attaque l'arrête devant le juge judiciaire). ⚠ Valable pour les usagers uniquement (pas accompagnateurs qui n'utilisent pas le service), CE 24 Nov. 1967, Labat ⚠ Les règlements relatifs à l'organisation et au fonctionnement des SP (tous) sont des AA, le contentieux de la légalité relève du juge administratif. tribunal des conflits, 15 Janv. 1968, époux Barbier. Ex. CE, 3 Oct. 2003, M. Peyron (Règlement tarifaire d'une station du ski) => Pas binaire: une question de responsabilité peut nécessiter une action à l'encontre d'un AA => question préjudicielle au juge administratif.

Agents fonctionnaires		
<u>Situation statutaire de droit public</u> (droits et obligations dépendent d'actes unilatéraux).		
Agents contractuels		
Géré par une personne privée	Géré par une personne publique	
	SPA	SPIC
• <u>Situation de droit privé</u> (contrat soumis au Code du travail); • <u>Juge judiciaire</u> (Prud'hommes jusqu'à CASS). Exception: agents sous statut (EDF/SNCF) qui disposent de textes spéciaux de droit privé (pas le C. Du travail).	• <u>Situation de droit public quelque soit l'emploi qu'ils occupent</u> Tribunal des conflits, 25 Mars 1996, Berkani Les seules exceptions résultent de la loi (Emploi solidarité, avenir, unique d'insertion, apprentissage).	• <u>Situation de droit privé</u> CE, 26 Janv. 1923, de Robert Lafregeyre Exception, CE 8 Mars 1957, Jalenques de labeau: Le directeur et le comptable du service si il a la qualité de comptable public

Section deux: Le régime juridique des services publics

§1- La création et la suppression des services publics

Principe = libre création et libre suppression

CE, 27 Janvier 1961, Vannier: Nul n'a, en principe, de droit acquis au maintien d'un service public

Il existe cependant des exceptions.

A) L'EXCEPTION DES SP OBLIGATOIRES

= Les SP constitutionnels; les SP régaliens (défense, police, justice ect.) ainsi que certains autres (éducation, sécurité sociale, hôpitaux).

= Ceux imposés par le législateur aux collectivités territoriales

Ex. SP départemental d'incendie et de secours, eau potable, pompes funèbres, ordures ménagères

CE, 24 Juin 2019, Commune de Fondenettes: La restauration scolaire, dans les écoles primaires et les collèges ne constitue pas un service public.
=> Sûrement le cas pour les lycées également.

CE, 21 Mars 2021 Commune de Besançon: Si le SP d'éducation existe, il s'exerce sous réserve des capacités d'accueil.

B) LA LIMITE DE LA LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Liberté de commerce et de l'industrie = traduction juridique de l'économie de marché

= liberté pour chacun d'exercer une activité économique sous réserves.

CE, 30 Mai 1930, Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers : « les conseils municipaux ne peuvent ériger des entreprises de cette nature en services publics communaux

que si, en raison de circonstances particulières de temps ou de lieu, un intérêt public justifie leur intervention en cette matière »

=> Règle de principe = exclusion de la compétence des personnes publiques.

(1) Le champ d'application du principe

Il est limité aux activités économiques.

3 catégories d'activités pouvant être considérées économiques sont hors de son champ d'application:

- Les activités nécessaires à la réalisation des missions dont sont investies les personnes publiques:

L'arrêt Chambre syndicale du commerce en détail de Nevers mentionne les SP communaux « de première nécessité se rattachant à l'hygiène, à la salubrité, à l'assistance ».

- Les activités répondant aux besoins propres des personnes publiques:

Ex. Boulangerie militaire qui livre un établissement pénitentiaire (CE, 29 Avril 1970, Société Unipain), prise de photos d'identité lors de l'instruction d'une demande de passeport lorsque la personne n'en a pas fourni (CE, 26 Oct. 2011, Association pour la promotion de l'image).

- Les activités constituant le complément, l'accessoire du service public existant :

Ex. Station service dans un parking public (CE, 18 Sept. 1959, Delansorne).

(2) L'exception au principe

= L'appréciation IN CONCRETO de l'intérêt public.

=> Justifie alors la création du SP économique

Pendant longtemps, la seule application de l'exception fut la carence (quantitative comme qualitative) d'initiatives privées.

Ex. CE, Section, 17 Avril 1964, commune de Merville-Franceville : Création d'un camping dans une station balnéaire où les places de camping privées ne répondaient pas à la demande. (Carence quantitative).

CE, 24 Nov. 1933, Zénard: Légalité de la création d'une boucherie municipale en raison des prix pratiqués par les bouchers.

Désormais, il ne fait pas doute que l'intérêt public peut aller au-delà de la seule carence de l'initiative privée.

CE 18 Mai 2005, territoire de la Polynésie française: Est illégal l'arrêt interdisant d'ériger la desserte internationale de la Polynésie française au seul motif d'une carence inexistante en l'espèce.

=> « la bonne desserte aérienne de la Polynésie française, indispensable à ses relations avec le reste du monde et à son développement, constitue un intérêt public local ».

§2- Les modes de gestion des SP

CE, 18 Mars 1988, Loupias: Les personnes publiques responsables d'un SP sont libres de son mode de gestion

= Principe.

CE, 6 Avril 2007, Commune d'Aix-en-Provence : Dressage d'une typologie des modes de gestion qui vient alors créer une distinction gestion directe/ gestion déléguée à un tiers.

Le détail n'est pas au programme du partiel. V. Cours sur Amétice pour le détail.

§3- Les principes de fonctionnement des services publics

A) LES LOIS DE ROLAND

Il existe trois grands principes qui **régissent le fonctionnement de tous les services publics**. On les regroupent sous l'appellation de **Lois de Roland**, systématisés par le Pr. Louis Roland.

« Ces règles générales de conduite, ces lois applicables toujours et nécessairement aux services publics sont peu nombreuses, il y en a trois: la loi de continuité, la loi de changement, la loi d'égalité ».

Nb. Ces principes sont un pouvoir de l'administration que des droits desquels les justiciables peuvent se prévaloir (ils peuvent parfois l'être mais assez peut, dans de rares cas).

CE, Section, 3 Juin 2022, Conseil national des barreaux : Pas d'invocabilité des droits de Roland comme droit.

(1) Le principe de continuité

= Signifie que les services publics ne doivent pas être anormalement interrompus.

La notion d'anormalité s'appréciant en fonction de l'objet de chaque service:

- SP qui fonctionnent en permanence (urgences, pompiers, eau, gaz) dont n'importe quelle interruption est considérée anormale;
- SP qui doivent seulement fonctionner aux heures et jours prévus par les textes qui les régissent (ex. Enseignement sup: 8h/20h du Lundi au vendredi hors vacances).

Cependant, il ne faut pas que les textes soient si restrictifs qu'ils portent atteinte au fonctionnement normal du service public.

CE, 25 Juin 1968, Vincent (ici bureau de poste aux horaires restrictives privant aux usagers d'un accès normal au service).

Exemples prétoriens:

- **CE, 13 Fev. 1987, Toucheboeuf**: Des parents d'élèves obtiennent l'annulation d'une décision mettant fin aux cours d'un collège pour permettre l'organisation du Bac pour violation du principe de continuité. (Contentieux de la légalité);
- **CE, 27 Janv. 1988, Ministre de l'éducation nationale**: Etre privé un temps certain d'un professeur alors que le Bac approche et qu'il s'agit d'une matière importante. Le bac est alors raté à cause de cette matière. On a une atteinte au principe de continuité du SP. (Contentieux de la responsabilité).

En réalité ce principe est moins un principe qui confère des droits aux usagers du SP qu'un principe permettant un atteinte au droit de grève des agents du SP.

Grève = atteinte à la continuité du service car cela porte atteinte à son fonctionnement.

=> Pendant longtemps, les agents du SP n'avaient pas le droit de grève au nom de la continuité de celui-ci (**CE, 7 août 1909, Winken**).

A l'époque, le droit de grève n'avait pas valeur constitutionnelle alors que le principe de continuité des SP oui.

La Constitution de 1946 consacre dans son préambule le droit de grève comme un droit constitutionnel. Le texte ne parle pas expressément des agents de SP mais **C. Constit., 25 Juillet 1979, droit de grève à la télévision et à la radio** le consacre pour les agents du SP.

On a donc deux principes constitutionnels qui s'opposent, il faut donc opérer une conciliation.

Compétence pour opérer la conciliation:

Al. 7 préambule de la Constitution de 1946: le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.

Le Parlement a donc compétence pour concilier les deux principes. Or, celui-ci n'a répondu que partiellement à la question.

Ex. certains SP uniquement ont interdiction légale de faire grève (police, magistrats...)).

Dans les cas où la loi ne répond pas à la question, deux réponses possibles:

- Logique (mais déconnectée de la réalité): seul le législateur peut limiter le droit de grève donc si pas de loi, l'agent peut faire librement grève.
 - Pragmatique, celle choisie par **CE, assemblée, 6 Juillet 1950, Dehaene** : Dans l'attente que le législateur intervienne, d'autres peuvent se substituer à lui.
 - => Ici, on permet à d'autres d'agir pour ne pas porter atteinte au principe de continuité (on ne va donc pas complètement en contradiction de l'alinéa 7).
 - => L'arrêt consacre la capacité du Gouvernement à intervenir en l'absence d'intervention du législateur (décret).
- Cependant, la JP consacre la capacité, si le gouvernement n'a pas agi, de l'autorité administrative responsable du service.

Opération de la conciliation :

Pour être légales, les limitations du droit de grève des agents du SP doivent être justifiées par 1) la poursuite d'un objectif légitime et 2) proportionnées pour atteindre cet objectif.

- => Objectif légitime = « éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public » (Dehaene) + **CE, assemblée, 12 Avril 2013, Fédération FO énergies et mines** : limiter des agents en vue de limiter les atteintes aux besoins essentiels du pays.
- => Proportionnalité: Ne doit pas aller au delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif.
Nb. Ici un contrôle normal de proportionnalité (vs. Arrêt Benjamin)

⚠ Il arrive que des limitations au droit de grève des services publics soient apportées par des autorités de police administrative et non pas l'autorité gestionnaire du service public.

(2) La loi de changement

= principe de mutabilité ou d'adaptabilité du SP.

Cette loi implique que le service public puisse toujours être adapté au changement qu'exige l'intérêt général.

- => Ces changements pouvant aller jusqu'à la suppression du service en question lorsque l'intérêt général le commande.

CE, 27 Janvier 1961, Vannier: il n'y a ni droit acquis au maintien d'un service public (exception faite pour les obligatoires)

Non plus de droit acquis au maintien de la réglementation qui régit le SP (sauf exception, le SP peut être supprimé et ses règles peuvent évoluer)

CE, 10 Janv. 1902, compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-rouen : Arrêt de principe

- => La commune délègue la gestion de l'éclairage public via un contrat de concession de SP de longue durée. Il est alors prévu un éclairage au gaz. La commune souhaite passer plus tard à l'électricité mais l'entreprise veut faire valoir le contrat; elle décide alors de résilier unilatéralement avant terme et avec effet immédiat le contrat. Selon elle, en refusant la demande d'évolution qui lui avait été faite, le concessionnaire avait commis une faute. Le CE valide alors cette thèse car le principe de mutabilité exigeait de faire évoluer le service indépendamment de ce que précisait le contrat si l'intérêt le commandait.
- => Les principes priment donc sur les clauses contractuelles.

CE, 11 Mars 1910, Compagnie générale française des tramways: La commune de Marseille avait souhaité reléguer ce SP à un tiers => construire l'infrastructure puis exploiter pour rentabiliser son investissement. Le contrat de concession prévoit la fréquence de passage des rames. Il y a de +

Reflexions:

Le droit administratif étant par essence équilibré, on donne ici des garanties à la partie privée: un contrôle juridictionnel de la validité d'un intérêt général et un droit d'indemnisation intégrale du préjudice que cause l'évolution imposée du service.

en + de monde l'été et leur nombre devient insuffisant. Le concessionnaire cherche donc à faire valoir le contrat. Ici, l'intérêt général commandait l'accroissement du nombre de tramways.

(3) Le principe d'égalité

Il n'est évidemment pas propre au régime des SP; c'est la facette d'un principe plus général: l'égalité devant la loi. C'est une facette qui été expressément consacrée dans **CE, Section, 9 Mars 1951, Société des concerts du conservatoire**. Il indique qu'il estime un principe général du droit d'égalité qui régit le fonctionnement des SP.

Ce principe implique une obligation de traitement égalitaire des personnes se trouvant une situation similaire. Ainsi, égalité de traitement des usagers ≠ identité de traitement des usagers. On ne traite pas tous les usagers de la même façon mais seulement ceux dans une situation similaire. Ainsi, le principe nullement de traiter de façon différente les usagers (ou candidats usagers) qui serait dans une situation différente.

Exemple prétorien:

- **CE, 10 Mai 1974, Denoyez et Chorques** : La différence tarif pour un service de transport en fonction du lieu de résidence est une différence de situation valable lorsque les habitants du lieu ont besoin de ce service (ici habitants de l'île de Ré oui mais les habitants de Charentes non).

Il faut que cette différence de situation soit 1) objectivement appréciable et 2) soit en rapport avec l'objet du SP.

CE, Section, 29 Dec. 1997, Commune de Gennevilliers: Même lorsqu'il n'y a pas de différence de situation pouvant justifier un traitement différent au regard du principe d'égalité, une discrimination peut être néanmoins jugée légale si elle est justifiée par un motif d'intérêt général.

=> En l'espèce, l'intérêt de tous à la culture (prix d'un conservatoire différencié en fonction des revenus).

Réflexions:

Le gestionnaire du service public PEUT traiter les usagers étants dans une situation différente. Mais n'existe-t-il pas un devoir, une obligation de la faire ? En droit de l'UE, le principe de l'égalité peut exiger de traiter différemment certaines personnes; en droit français, la JP est claire: le principe de l'égalité permet mais n'oblige pas de traiter différemment des personnes dans des situations différentes. On peut tenir compte de la réalité mais on n'est pas tenu de le faire (pas de droit à la différence). **CE, Assemblée, 28 Mars 1997, Société Baxter**.

En droit français, il y a des critères de distinction formellement prohibés quand bien même il serait utilisé pour aider (cas de discrimination positive). Ils sont les 3 mentionnés à l'article premier de la Constitution: distinction d'origine, de race, de religion.

Principe d'égalité ≠ principe de non discrimination

On a une différence de champ d'application personnelle: Le principe d'égalité ne s'impose qu'aux personnes publiques (et personnes privées en charge du SP) alors que le principe de non discrimination s'impose à toutes personnes.

On a une différence de contenu matériel: Le principe d'égalité oblige à faire pas un qui interdit de faire (principe positif) tandis que la non discrimination interdit de traiter différemment des personnes sur la base de certains critères prohibés (ils sont nombreux mais les listes sont limitatives en fonction des branches du droit).

L'inégalité peut être justifiée soit par une différence de situation soit par un motif d'intérêt général.

B) LES AUTRES PRINCIPES DU SP

(1) L'absence du principe de gratuité

Hauriou soutenait qu'il y en avait un quatrième: le principe de gratuité.

Or, en droit positif, hors cas prévus par la loi, il n'existe pas de principe de gratuité du SP. En effet, les SPIC ne sont, par essence même, pas des services gratuits (critère jurisprudentiel de financement du service) mais c'est également le cas des SPA. [CE, Assemblée, 10 Juillet 1996, Société Direct Mail Promotion](#) refuse en effet de consacrer ce principe.

Le paiement d'un SP peut être organisé selon deux conditions posées par [CE, 28 Nov. 2018, Réseau ferré de France](#):

- Les opérations financées par la redevance ne doivent pas incomber à l'Etat ou aux personnes publiques.
Ex. Les missions de surveillance et sécurité des usagers sur les autoroutes ne peuvent être financées par les redevances payées par les automobilistes ([CE, Assemblée, 30 Oct. 1996, Mme Wajs et Monnier](#)).
- La contrepartie de la redevance doit bénéficier à des usagers déterminés.
Ex. Contrôle, surveillance et gardiennage des trains de marchandises avant d'emprunter le train sous la manche ([CE, 18 Nov. 2018, RFF](#)).

⚠ Il est possible pour l'organisateur d'un événement privé de payer un SP de nature gratuite lorsque la prestation va au delà de la prestation normale.

Ex. [Art. 23 Loi du 23 Juillet 1995](#) qui oblige les organisateurs de manifestations sportives de « rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supporté dans leur intérêt ».

En revanche, le remboursement est limité à l'équivalence avec la valeur de la prestation ([CE, ass., 16 Juillet 2007, Syndicat national de défense Del 'exercice libéral de la médecine à l'hôpital](#)).

En revanche, les SP peuvent être gratuits lorsqu'un texte le prévoit.

Ex. [Alinéa 13, Préambule de la Constitution du 1946](#): enseignement public gratuit, laïque.

(2) Le principe de neutralité du SP

Il y a cependant bien un quatrième principe: le principe de neutralité du SP. Ce principe est clairement consacré par CE. Le principe a une double dimension: politique et religieuse (le SP ne doit pas être associé à une idéologie politique ou une idéologie religieuse).

Le principe de neutralité religieuse des SP découle du principe de laïcité (lui-même consacré à Art. 1, C de 1958). Les agents du SP y sont soumis alors que les usagers, en principe, n'y sont pas soumis.

- Le principe de neutralité religieuse s'applique donc aux agents du service public:

Un agent du SP étant représentant du SP et de l'Etat, il est logique que les agents soient soumis aux principe de neutralité religieuse tant ce principe découle de la laïcité.

Tous les agents des SP sont soumis à ce principe (SPA ou SPIC, personne privée ou publique, fonctionnaire ou contractuel de droit public comme privé, tous sont soumis au principe de neutralité religieuse).

[CE, 3 Mai 2000, Avis Mlle Marteaux](#): Surveillante contractuelle porte le voile et le chef d'établissement lui demande de l'enlever. Elle considère son licenciement abusif.

[CE, 28 Juillet 2017, Mme C.](#): Champ d'application large et s'applique même à des stagiaires (infirmières en stage => double statut).

Le fait que le principe s'étende aujourd'hui aux agents de personnes privées chargées de SP est aujourd'hui validé par la [loi du 24 Aout 2021 confortant les principes de la République](#).

Exemple: maman qui accompagne une sortie scolaire n'est ni agent ni usager, elle est un collaborateur occasionnel du SP. Le principe de neutralité religieuse s'applique-t-il ? Le principe découlant de la laïcité, ne sont soumis au principe que les représentants de l'Etat donc on peut penser qu'elle n'y est pas soumise (validé implicitement par [CE, 23 Dec. 2013](#)). La seule exception pouvant être faite lorsqu'elle est à l'intérieur des locaux.

Exemple: joueuse de l'équipe de France de football. Techniquement elle ne participe à l'exécution des missions du SP de FFF donc elle n'est pas un agent mais il n'est pas non plus absurde de soumettre les joueurs au principe de neutralité religieuse car ces joueurs sont considérés par le grand public comme représentant la nation. ([CE 29 Juin 2023, Association alliance citoyenne](#)).

Ces atteintes à la liberté de religion sont estimées justifiées et proportionnées par la CEDH comme la CJUE (dès lors que toutes les religions sont regardées de manière indéterminée).

=> Une difficulté se porte sur la caractérisation de la « manifestation d'une conviction religieuse » à travers les vêtements, bijoux ect.

[CAA Paris, 18 Oct. 2024, M. B.](#): Il voulait devenir fonctionnaire de police et se voit refuser le droit de participer au concours de police au motif qu'il aurait sur le front une marque physique indélébile qui témoignerait de son appartenance religieuse (une tabaa). La cour juge que ce signe n'est pas incompatible avec le principe de neutralité religieuse, cette marque ne témoignant pas d'une volonté d'exprimer ses convictions religieuses.

En dehors de leur fonctions, les agents du SP peuvent en principe exprimer leur appartenance religieuse comme ils le souhaitent; c'est à la fois vrai et faux-

- Vrai car le principe ne s'applique aux agents que dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions;
- Faux en raison du devoir de réserve des fonctionnaires: un agent, même en dehors de ses fonctions doit faire preuve d'une certaine modération dans l'expression de ses convictions politiques ou religieuses, l'appréciation de cette modération est faite IN CONCRETO (en fonction du poste, du type de déclaration ect.).

Ex. Il est exclu, pour un agent du SP, alors même qu'il travaille pour une personne privée, puisse publier des messages appelant à la diffusion de sourates du Coran appelant à la violence sur Facebook.

- Les usagers du SP ne sont pas soumis au principe de neutralité religieuse

Ce principe ne leur est pas applicable. Pour les usagers, le principe est donc la liberté de manifestation religieuse. C'est logique car ce principe découle de la laïcité qui n'implique que la neutralité religieuse de l'Etat (au sens large; donc ceux qui le représentent). Ainsi, la laïcité ne saurait s'appliquer à ceux qui ne représentent pas l'Etat.

Cependant, aucune liberté n'est absolue; elle peut donc être parfois limitée et ceux dans deux cas:

- Là où la loi restreint cette liberté ;

Seule application: [Loi du 15 Mars 2004](#) qui interdit aux élèves des écoles, collèges et lycées publics de manifester de manière ostensible leur appartenance religieuse.

Remarque: la loi s'intitule application du principe de laïcité ainsi ce titre va à l'encontre du fonctionnement même de principe de laïcité en France.

Sur sa compatibilité avec la CESH: ø d'atteinte excessive à la liberté de religion car la mesure est justifiée (car usagers mineurs donc influençables) et proportionnée (l'enseignement est obligatoire mais l'enseignement public n'est pas lui obligatoire, il existe des alternatives).

- Là où le règlement du SP l'interdit: le personne en charge du SP peut adopter un règlement restreignant la liberté des usagers de ce service dans deux cas: 1) Lorsque l'expression ou la

manifestation religieuse risque de nuire au bon fonctionnement du SP 2) Lorsque l'exercice de la liberté religieuse par certains usagers est de nature à porter atteinte aux droits et libertés d'autrui.

Consacré par CE, Avis, 27 Nov. 1989, affaire des jeunes filles voilées de Creil; CE, 2 Nov. 1992, Kherouaa Ces arrêts posent un principe de liberté pour les usagers du SP + des limites hors loi spéciales (limites par le règlement).

=> Ces deux références sont à la fois datées (car concernaient des usagers d'établissements scolaires publics) et d'actualité (les principes posés sont toujours valables pour les usagers des SP non soumis à une loi particulière).

Exemple: CE, 29 Juin 2023, Association alliance citoyenne: règle en cause = règle édictée de la FFF interdisant à ses licenciés de porter un signe ou un vêtement religieux lors des matches (ici amateurs). Ces joueuses sont des usagers du SP donc le principe est la liberté. Le CE considère que la règle est légale car le port de signes religieux aurait pu nuire au bon fonctionnement du SP (de par de considération sécuritaires: prévenir affrontements ou confrontations sans lien avec le sport).

=> On admet ici la limite de la liberté religieuse car des personnes extérieures (public ou équipe adverse) pourraient ne pas supporter la liberté religieuse (c'est philosophiquement discutable) + le risque que le port d'un voile puisse susciter des confrontations est purement hypothétique, or normalement, pour limiter les libertés, le risque doit être réel et non pas imaginaire (réellement discutable). Or ici, la FFF n'était ø capable de reporter un seul incident + autorisé dans d'autres sports et dans d'autres pays. Le risque n'était donc pas avéré mais a suffi à justifier une atteinte à la liberté religieuse des usagers d'un SP.

=> Arrêt potentiellement dangereux car rédigé de façon à ce qui a été appliqué pourrait s'appliquer dans d'autres circonstances.

Saur la différence entre les usagers: Sauf exception, un gestionnaire de SP n'est pas obligé de tenir compte des différences religieuses entre usagers (il peut même refuser d'en tenir compte si la décision est motivée) mais rien n'interdit de le faire.

=> Se cacher derrière la laïcité n'est donc qu'un faux prétexte.

Titre second: Les actes de l'administration

Pour pouvoir mener à bien les missions qui sont les siennes, l'administration peut agir juridiquement de deux manières: par voie de commandement ou par voie de consentement. Il existe toute fois des cas où l'administration n'a pas le choix du moyen juridique d'action (matières hors du champ contractuel); sauf cas particuliers, l'administration a donc le choix entre les actes unilatéraux et les contrats.

Chapitre 1: Les contrats administratifs

Lorsque l'on pense contrat, on ne pense pas a priori à l'administration. Or, le procédé contractuel est un procédé traditionnel et usuel de l'action administrative (depuis longtemps et souvent).

Quelques exemples: délégation de SP, marchés publics (biens, service, travaux dont elle a besoin), recrutement de personnel de l'administration...

Tous les contrats que conclue l'administration ne sont pas des contrats administratifs. Les contrats conclus par l'administration sont donc tantôt des contrats administratifs et tantôt des contrats de droit privé.

Face à un contrat passé par l'administration, la première difficulté est donc la qualification de celui-ci qui déterminent le juge applicable.

Section une: la qualification de contrat administratif

Dans certains cas, la qualification est simple: la réponse est donnée par le législateur. Certains contrats sont donc administratifs par détermination de la loi.

§1- L'identification jurisprudentielle des contrat administratif

Pour qualifier/ exclure le contrat administratif dans le silence de la loi, il faut recourir à des critères jurisprudentiels.

Deux critères doivent être cumulativement réunis pour qualifier le contrat d'administratif: organique et matériel.

A) LE CRITÈRE ORGANIQUE DU CONTRAT ADMINISTRATIF

C'est le critère tiré de la nature juridique des parties au contrat. On regarde donc qui a passé le contrat. Il faut en principe qu'il y ait au moins une personne publique partie au contrat pour satisfaire ce critère.

=> Un contrat conclu entre des personnes privée uniquement ne peut pas, en principe, être administratif (**Tribunal des conflits, 3 Mars 1969, Société interprofessionnelle du lait**).

=> Peut importe que l'une des personnes privée soit chargée de SP ou délégataire de SP

Toutefois, le principe connaît deux exceptions qui relèvent de deux catégories (**Tribunal des conflits, 8 Juillet 2013, société d'exploitation des énergies photovoltaïques**):

Considérant que les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, **hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public**; que, d'une part, par le contrat de raccordement d'une installation de production d'électricité

(1) Les personnes privées agissant pour le compte d'une personne publique

= Hypothèses où le contrat n'est pas formellement signé par une personne publique mais par une personne privée qui, d'une façon ou d'une autre, peut être regardée comme l'intermédiaire d'une personne publique. Cela regroupe deux cas, auparavant trois:

- Les personnes privées transparentes

= Prolongement d'une personne publique

=> Le personne doit être créée, financée, organisée et contrôlée par une personne publique.

=> Généralement une association.

La personne privée existe formellement mais elle n'est en réalité que la chose de la personne publique.

Lorsqu'un contrat est passé entre la personne privée transparente et une autre personne privée, on considère que le lien organique est satisfait (CE, 21 Mars 2007, commune de Boulogne Billancourt, arrêt de principe).

L'intensité du lien exigé par APREI et Boulogne de Billancourt n'est pas le même: pour satisfaire Boulogne de Billancourt, il faut satisfaire un lien très fort.

⚠ Les SPL ne sont pas une personne privée transparente (tribunal des conflits, Société Guyacom).

- Les personnes privées mandataires d'une personne publique

Le mandat dont peut bénéficier une personne privée pour agir au nom d'une personne publique peut être de deux types:

- Le mandat civiliste, classique (au sens de C. Civ. 1984): CE, Section, 2 Juin 1961, Leduc.
- Le mandat « administratif »/« tacite » (qualification doctrinale): Il va lui se deviner (il n'est ø express) des clauses d'un contrat qui n'a pas expressément pour objet de confier mandat à une personne privée. Tribunal des conflits, 7 Juillet 1975, commune d'Agde + CE, Section, 30 Mai 1975, société d'équipements de la région Montpellier Rennes

=> Se déduit d'une série d'indices

« La théorie du mandat administratif constitue à la fois une forme dégradée du mandat au sens du Code civil et une forme affaiblie de la transparence » - Magistrats du CE

Si la même situation qu'en 1975 venait aujourd'hui à être soumise au juge administratif serait différente car le champ d'application du mandat administratif a été réduit (aujourd'hui, exclusion de la théorie lorsque le co contractant agissant possiblement pour la personne publique est liée à la personne publique par un contrat de concession, Tribunal des conflits, 11 Dec. 2017, commune de cap breton).

Exemple: Arrêt ADP: En passant ses contrats pour les besoins de la sécurité de l'aéroport (société privée qui s'occupe de la sécurité), la société ADP agit par mandat administratif.

- Les concessionnaires autoroutiers

= personnes privées qui, par un contrat de concession vont exploiter une autoroute

JP ancienne: Tribunal des conflits, 8 Juillet 1963, Société entreprise Peyrot: Les contrats passés par les sociétés privées concessionnaires d'autoroutes avec d'autres personnes privées pour la réalisation de travaux autoroutiers étaient considérés comme des contrats administratifs.

=> Car on considère que comme ça sont des voies de communication essentielles, par leur nature, ces contrats relèvent de l'Etat.

=> Travaux autoroutiers = tous travaux concernant l'autoroute

Revirement de JP: **tribunal des conflits, 9 Mars 2015, Rispal**: Mets fin à société entreprise Peyrot. On applique les critères classiques sans faire de cas particulier de ces contrats.

=> Rispal mets fin à entreprise Peyrot vaut pour les contrats signés après le 9 mars 2015. L'arrêt nouveau n'agit pas sur les contrats conclus dans le passé.

(2) Les contrats accessoires à un contrat principal

Lorsqu'un contrat est accessoire à un contrat principal, peut importe pour sa qualification qu'il soit conclu entre deux personnes privées puisque le contrat accessoire aura la même nature que le contrat principal.

=> ∅ nécessaire de regarder les critères sur le contrat accessoire. Si le contrat principal est administratif, le contrat accessoire l'est.

Un contrat accessoire est un contrat qui n'a de raison d'être que la conclusion ou l'exécution d'un autre contrat.

Ex. Un contrat de financement d'un marché public.

B) LE CRITÈRE MATÉRIEL

Il se subdivise en trois sous-critères qui ne sont pas cumulatifs. Il est rempli dès lors qu'un sous critères l'est.

(1) Les clauses du contrat

Pour considérer que le critère matériel est satisfait, on doit trouver **au moins une clause exorbitante du droit commun**.

CE, 31 Juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges (arrêt de principe):

Remarque: si l'idée est présente dans l'arrêt (l'expression n'est pas utilisée), elle se déduit à contrario de la décision.

=> En l'espèce, le juge constate qu'il n'y a que des clauses que l'on trouve classiquement dans les contrats entre particulier et que le contrat n'est donc pas administratif.

Pendant longtemps, la JP n'a donné qu'une définition négative des clauses exorbitantes du droit commun:

CE, Section, 20 Oct. 1950, Stein : Clause ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou mettre à leur charge des obligations, étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptible d'être librement consenti par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales.

=> Clauses qui seraient impossibles/illicites/ inhabituelles dans les relations contractuelles entre particuliers.

Ex. **CE, 26 Fev. 1965, Société du vélodrome du parc des princes**: clause qui donne à la mairie de paris un pouvoir de résiliation unilatérale du contrat pour motif d'intérêt général.

=> Définition négative car donnée par rapport au droit privé.

La définition négative posait des difficultés car elle reposait sur une comparaison avec ce qui ne se fait pas en droit privé.

Tribunal des conflits, 13 Oct. 2014, société Axa France (définition positive): Clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

=> Pour déterminer si une clause mérite d'être qualifiée exorbitante du droit commun, il faut recourir à une approche finaliste, il faut se demander en quoi la prérogative est reconnue à l'administration contractante.

=> S'il apparaît qu'un pouvoir est reconnu à l'administration pour servir l'intérêt général, alors c'est une clause exorbitante au droit commun.

Exemples: **Tribunal des conflits, 12 Fev. 2018, SARL the Congress house**: Une commune met à disposition d'une société privée une salle de spectacle municipal pour y organiser des événements culturels. Ici, deux clauses reconnaissent à la commune des prérogatives (droit de regard sur la programmation au sein de la salle + elle peut récupérer la salle pour ses propres besoins 12x/an et 2x/mois à condition de prévenir la société). Ici, les prérogatives satisfont l'intérêt général.

Tribunal des conflits, 4 Juillet 2016, société generim c. Ville de Marseille : La ville cède un parcelle communale (contrat de vente) mais il est prévu que la personne privée devra, sous possibilité de résoudre le contrat, bâtir ou faire bâtir sur cette parcelle un hôtel qui devra être maintenu pendant au moins 10 ans. Ici, ø de clause exorbitante du droit commun (elle ne reconnaît pas un pouvoir à l'administration + pouvoir de résiliation ne sert pas nécessairement un intérêt général).

Pour savoir si une clause est exorbitante du droit commun, il faut se livrer à une appréciation IN CONCRETO: une même clause peut dans certains cas être exorbitante du droit commun et dans d'autres non.

Ex. Résiliation unilatérale au profit de l'administration, parfois oui parfois non (de par l'approche finaliste).

Tribunal des conflits, 2 Nov. 2020, société eveha: Une clause bénéficiant au cocontractant privé, même dans l'intérêt général, ne saurait être qualifiée exorbitante au droit commun. La cause exorbitante du droit commun ne peut être qu'une clause bénéficiant à l'administration.

NB. Chapitre 2: **CE, 13 Oct. 1961, établissement campanom-rey & tribunal des conflits, 17 Dec. 1962, Dame Bertrand**: Les usagers de SPICs sont dans une situation contractuelle de droit privé. Cette règle tiens en échec les règles que nous venons de voir.

=> Le contrat conclu entre l'utilisateur d'un spic et son gestionnaire est toujours un contrat de droit privé.

(2) L'objet du contrat

= ce sur quoi il porte; l'opération qu'il permet de réaliser (travaux, vente, location, embauche...).

Pour que l'objet lui confère un caractère administratif, il faut que celui-ci soit suffisamment en lien avec l'exécution d'un service public. Ce critère a été dégagé avant celui des clauses puis a disparu de la jurisprudence avant de renaître.

Jurisprudence de principe: **CE, 4 Mars 1910, Thérond**
Renaissance: **CE, section, 20 Avril 1956, époux Bertin**

Il y a 4 cas de figure où l'objet peut être en lien avec le SP.

- Les contrats confiant au cocontractant de l'administration l'exécution même d'un SP

= Contrats de délégation du SP à une personne privée. Par leur objet, ils sont en lien évident avec l'exécution d'un SP.

C'est le cas de Bertin et Thérond

Nb. Il faut bien appliquer Nancy et/ou APREI avant pour s'assurer de l'existence du SP.

Les arrêts Thérond et Bertin sont importants du point de vue doctrinal mais qu'assez peu en pratique car les contrats de délégation de SP sont, en majorité, des contrats administratifs par détermination de la loi.

- Les contrats constituant une modalité même de l'exécution d'un SP

CE, 20 Avril 1958, Grimouard: SP du reboisement, il faut passer des contrats avec des propriétaires privés pour planter des forêts sur les terrains de ceux-ci. Ces contrats continuent une modalité de l'exécution du SP.

- Les contrats de recrutement dans les SPAs gérés par des personnes publiques

Un contrat par lequel une personne publique gérant un spa recrute un agent est administratif de part son objet (**tribunal des conflits, 25 Mars 1996, Berkami**).

- Les contrats associant le cocontractant de l'administration à l'exécution d'un SP

Ici, la JP réponds au cas par cas et pas toujours subjective (pas évident de savoir si la personne privée est associée à l'exécution d'un SP ou non).

Exemple: Contrats que concluent les hôpitaux publics pour la location de téléviseurs destinés aux chambres des patients. Sont-ils administratifs ?

CE, 8 Juin 1994, Société Codiam: Oui

Tribunal des conflits, 21 Mai 2007, société Codiam: Non

CE, 2 Mai 2016, CHU de Montpellier

(3) Le régime du contrat

Un critère important en théorie mais beaucoup moins en pratique.

Ce critère découle de **CE, 19 Janv. 1973, société d'exploitation électrique de la rivière du Sant**: EDF passe des contrats avec des producteurs autonomes d'électricité pour racheter l'électricité produite. Le juge remarque que l'on ne sait pas si ces contrats sont de droit privé ou public mais remarque qu'ils sont partiellement régis par un texte spécial (décret) qui pose des règles particulières exorbitantes du droit commun. Le juge indique qu'il s'agit d'un contrat administratif.

=> Lorsqu'un contrat (non qualifié par la loi) est régi partiellement à un régime exorbitant du droit commun par un texte, ce contrat est qualifié administratif.

C) LES CAS PARTICULIERS

= cas où ø de qualification législative et où le juge n'applique pas les critères habituels

Cela concerne plusieurs types de contrats:

- Les contrats de transaction { par lequel les parties mettent fin à un litige sans recourir au juge}. Le juge utilise une autre méthode qui découle de **tribunal des conflits, 18 Juin 2007, société Briançon bus**: le juge se base sur la nature du litige à l'origine du contrat.
 - Les contrats conclus entre personnes publiques: le contrat applique **Tribunal des conflits, 21 Mars 1983, UAP**: présomption d'administrativité de ces contrats.
- => La présomption n'est pas irréfragable: renversée quand eu égard à son objet, le contrat le fait naître que des rapports de droit privé.

Ex. Fac et EDF pour la distribution de l'eau est de droit privé.

Nb. Certaines juridictions de fond n'utilisent pas cette méthode particulière.

§2- Les contrats administratifs par détermination de la loi

C'est la cas pour:

- Les contrats comportant occupation du domaine public (**art. L. 2331-1, Code général de la propriété des personnes publiques**);
- Les contrats de cession de biens immobiliers de l'Etat (**art. L. 3331-1, Code général de la propriété des personnes publiques**);
- Les marchés publics et des concessions passés par des personnes publiques (**article L6 du code de la commande publique**);

Ce sont les contrats par lesquels des personnes publiques ou assimilées se procurent des ouvrages, des biens meubles, ou bénéficient de prestations de service. Le critère distinctif étant le risque d'exploitation: le marché public est un achat (le titulaire du marché ne risque rien) et la concession est une exploitation (le concessionnaire voit sa rémunération

dépendre de l'exploitation du service (concession de service) ou de l'ouvrage construit (concession de travaux).

- Les contrats d'achat d'électricité conclus entre EDF et les producteurs autonome d'électricité (Loi du 12 Juillet 2010).

A l'inverse, certains contrats sont qualifiés de droit privés par la loi: contrats emploi solidarité, contrats d'avenir, contrats uniques d'insertion, contrat d'apprentissage, etc.

⚠ Les contrats administratifs déterminés par la loi peuvent être soumis à un régime particulier prévu par la loi.

Ex. les marchés publics, les concessions, et même dans une certaine mesure les contrats d'occupation du domaine public soumis à des procédures de passation, notamment de mise en concurrence.

Section deux: Le régime juridique des contrats administratifs

Les contrats de droit privé de l'administration sont soumis aux droits civil et commercial. On ne s'intéresse donc qu'au régime des contrats administratifs. Ce régime n'est pas totalement original; sur certains points, il n'est que la transposition du droit civil. Un contrat administratif reste un contrat.

⚠ Certains contrats administratifs sont soumis à un régime spécial (ex. Code de la commande public). Nous allons donc étudier le régime général des contrats administratifs.

Ce régime ne découle pas de textes mais bien de la jurisprudence. Ces règles sont applicables au contrat administratif même en l'absence de clause du contrat les rappelant.

Ce régime est constitué de deux catégories de règles qui font écho au caractère, par essence, inégalitaire du droit administratif.

§1- Les prérogatives exorbitantes de l'administration contractante

De par l'intérêt général, il est nécessaire que ce contrat soit équilibré, puisse évoluer, y mettre fin si l'intérêt général le commande.

Ces prérogatives sont au nombre de trois.

A) UN POUVOIR DE CONTRÔLE ET DE SANCTION

Par ce qu'un contrat administratif a un rapport avec l'intérêt général, il est nécessaire qu'il soit exécuté et bien exécuté. Ainsi, l'administratif dispose d'un pouvoir permettant de contrôler l'exécution d'un contrat voire en sanctionner l'inexécution.

- Inexécution contractuelle du cocontractant

Le pouvoir de contrôle peut prendre plusieurs formes:

- Demandes de documents (bon de commande, bilan...);
- Visites du lieu d'exécution du contrat.

Ce peut importe que cela soit prévu ou non au contrat (dès lors que la demande est raisonnable).

=> Pas de JP de principe

Le pouvoir de sanction est celui de la sanction des fautes du cocontractant. CE, 31 Mai 1907, Deplanque (arrêt de principe).

Les sanctions envisageables sont:

- (Pécuniaire mais elles doivent être prévues par une clause du contrat, elles ne découlent pas simplement du régime général du contrat administratif;)

- Mise en régie ou mise sous séquestre: des sanctions par lesquelles l'administration après mise en demeure infructueuse va soit se substituer au cocontractant (régie) ou substituer un tiers (séquestre);
- => Se fait aux frais du cocontractant défaillant (l'administration envoie la facture ensuite).
- La résiliation unilatérale du contrat (terme définitif au contrat). Le cocontractant n'a droit à aucune indemnisation (sauf lorsqu'il a réalisé des investissements qui n'ont pas été amortis)

Difficulté relative aux contrat de concession de SP: pendant longtemps, il a été jugé que la résolution unilatérale pour faute était trop lourde (en l'absence de clauses le prévoyant), elle ne pouvait donc pas être appliquée. Il fallait donc qu'elle soit prononcée par le juge.

- => Puisque ces contrats sont de longue durée, que celle-ci est justifiée par le fait que le cocontractant a réalisé de lourds investissements. (don de garanties au cocontractant).

Depuis **CE, 12 Nov. 2015, Société le jardin d'acclimatation**: l'administration dispose depuis d'une option de résiliation unilatérale en plus de l'option de résolution devant le juge (concernant les concessions de SP).

- Inexécution contractuelle de l'administration

CE, 7 Janv. 1976, Ville d'Amiens: Pas d'exception d'inexécution (si tu fais pas j'ai le droit de pas faire) sauf dans le cas où une clause du contrat le prévoit expressément.

- => Il n'y a pas de raison que les citoyens fassent les frais d'une telle inexécution (ø d'arrêt du service).

Si le cocontractant ne peut pas arrêter d'exécuter le contrat, il peut en revanche saisir le juge administratif d'une action en responsabilité contractuelle.

CE, 8 Oct. 2014, Société grenke locations: continue de faire progresser les droits du cocontractant en autorisant la clause permettant au cocontractant de l'administration de résilier unilatéralement le contrat en cas de faute grave de l'administration sous certaines conditions:

- Pas dans tous les contrats administratifs (notamment dans les contrats qui ont pour objet l'exécution même d'un SP);
- Obligation de mise en demeure préalable de l'administration;
- Possibilité d'opposition de l'administration en invoquant un motif d'intérêt général.
- => Possibilité de contrôle par le juge administratif de la réalité du motif d'intérêt général

B) LE POUVOIR DE MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT

En vertu des règles générales applicables au contrat administratif même en l'absence de clauses le prévoyant, l'administration peut, seule, modifier une ou plusieurs clauses d'un contrat administratif en cours d'exécution.

- => D'abord reconnu pour les seules concessions de SP (v. Loi de mutabilité, Arrêts de 1902 et 1910).
- => Vaut pour tous les contrats administratifs depuis **CE, 2 Fev. 1983, Union des transports publics urbains et régionaux** (Extension du principe des arrêts précédents).

Le contrat est la loi des parties et résulte d'un ensemble de consentements, ainsi ce principe connaît plusieurs limites pour éviter que l'administration n'abuse de ce pouvoir:

- Elle ne peut l'utiliser que lorsque l'intérêt général le commande (sous réserve d'interprétation par le juge);
- Elle ne peut modifier la nature globale du contrat (portée limitée de l'usage de ce pouvoir).

Exemple de modifications impossibles: l'objet du contrat, un changement qui provoquerait un bouleversement de l'économie du contrat.

- Le préjudice causé par la modification légale unilatérale du contrat peut être intégralement indemnisé.

C) LE POUVOIR DE RÉSILIATION UNILATÉRALE

Rappels sur **CE, 10 Janv. 1902, compagnie nouvelle du gaz de Deville-lès-rouen**: La société est en charge de l'éclairage public et refuse de passer du gaz à l'électricité. Ici, l'intérêt général est caractérisé mais on peut se demander si on est pas face à une modification de l'objet du contrat (gaz ≠ électricité surtout à l'époque).

- => Le CE considère qu'il s'agit d'une vision technique et pas de l'objet du contrat (éclairage public).
- => Sur l'objet du contrat, le CE peut donc être sévère.
- => Erreur juridique de l'entreprise: l'administration a résilié pour faute le contrat car la compagnie avait refusé d'exécuter le contrat alors que si elle s'était exécutée, elle aurait été indemnisée intégralement.

Ici, il faut distinguer de la résiliation unilatérale pour sanction. C'est ici la résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général. Le cocontractant exécute correctement le contrat mais l'intérêt général le commandant, l'administration résilie tout de même le contrat.

- => Jp de principe: **CE, assemblée, 2 Mai 1958, Distilleries de Magnac-Laval & CE, 31 Juillet 1996, Société des téléphériques du massif du Mont blanc**.

Ex. **CE, 19 Janv. 2011, Commune de Limoges**: contrat de convention d'occupation du domaine public avec une personne privée pour une activité de bar/restaurant. L'administration veut récupérer le bien pour ériger l'activité en SP et le gérer en régie.

- => Ici caractérisé comme motif d'intérêt général justifiant la résiliation unilatérale de la convention domaniale.
- => Illustre aussi que la création de SP par les collectivités territoriales peut ne pas porter atteinte à la liberté de commerce et d'industrie.

Plusieurs doutes en lien avec ce droit ont été levés par levés:

CE, assemblée, 2 Fev. 1986, Société TV6: Possibilité de résiliation pour les contrats de concession de SP.

Pour les contrats conclus entre deux personnes publiques, les intérêts généraux protégés par chacune de ces personnes sont donc en concurrence.

Question résolue par **CE, 27 Fev. 2015, Commune de Béziers**: le pouvoir reste utilisable mais le juge apprécie strictement l'intérêt général qui en résulte.

- => Concrètement seuls deux principes sont retenus pour justifier la résolution unilatérale: la disparition de la cause du contrat et le bouleversement de l'équilibre économique du contrat.

Lorsqu'une partie à un contrat doit faire face à la résolution unilatérale de celui-ci pour un motif d'intérêt général, elle a le droit à une indemnisation intégrale. Ainsi, s'il y a une inégalité de droit, le droit administratif s'efforce d'être équilibré (réparation du préjudice).

- => **CE, 19 Dec. 2012, Société AB Trans**: Permet désormais d'insérer dans les contrats administratifs des clauses prévoyant une indemnisation inférieure au préjudice réel en cas de résiliation unilatérale.
- => Donc questionnement sur la rupture de l'équilibre entre pouvoir de l'administration et garantie des administrés.
- => On relèvera également que la liberté contractuelle est ici à géométrie variable: possibilité de clause prévoyant une indemnisation inférieure mais **CE, 4 Mai 2011, CCI de Nîmes** considère qu'une clause prévoyant une indemnisation supérieure est illégale (au nom du principe d'interdiction des libéralités (interdiction de cadeaux financiers aux administrés)) + exclusion du droit de résiliation unilatérale de l'administration (**CE, 6 Mai 1985, Association eurolat**).

§2- Les garanties particulières du cocontractant

Dans le régime général du contrat administratif, les cocontractants disposent de protections particulières même en l'absence de clauses du contrat le prévoyant.

Ces garanties tournent autour de la même idée: sauf faute de sa part, le cocontractant a droit à l'équilibre financier du contrat.

Exemples :

- Une startup cherche des locaux, pour faire son choix, elle se base, entre autres, sur la fiscalité locale. L'entreprise choisit une commune qui, quelques années après, augmente considérablement les impôts locaux.
=> Le préjudice résulte bien d'une mesure imprévue de l'administration contractante en tant qu'autorité administrative. Il bouleverse l'économie du contrat. Or, tous les contribuables (dont les entreprises) font face à l'augmentation d'impôts donc le préjudice n'est pas spécial.
- Contrat de délégation de SP entre une commune et une société de bus. La commune décide de changer les conditions de circulation dans la commune. Ici, si la mesure est générale, le préjudice est bien spécial car la société y perd bien une somme conséquente.

Ce droit à l'équilibre financier du contrat prend des formes diverses. Le cocontractant de l'administration peut aussi avoir droit à une indemnisation lorsque surviennent certains aléas dont l'administration n'est pas responsable.

=> Peuvent être techniques, administratifs ou économiques

Chacune de ses catégories d'aléa peut ouvrir droit à indemnisation en vertu de droit théories jurisprudentielles distinctes:

- Aléa technique = théorie des sujétions imprévues

=> Elle ne joue quasiment que pour les marchés de travaux (contrats administratifs spéciaux).

- Aléa administratifs = théorie du fait du prince

- Aléa économique = théorie de l'imprévision

A) LA THÉORIE DU FAIT DU PRINCE

⚠ L'expression « fait du prince » n'a pas ici le même sens que dans d'autres branches du droit (donc ≠ droit civil).

En droit des contrats administratifs, le fait du prince est une mesure imprévue prise par l'administration contractante en tant qu'autorité administrative et qui, bien que licite, a des répercussions financières sur les conditions d'exécution du contrat. Dans le cas où une telle mesure causerait un bouleversement de l'économie du contrat, le cocontractant a droit à une indemnisation intégrale du préjudice causé par le fait du prince.

Pour avoir droit à une indemnisation intégrale sur le fondement de cette théorie, le cocontractant doit faire état d'un préjudice spécial.

B) LA THÉORIE DE L'IMPRÉVISION

= Circonstances extérieures aux parties et imprévisibles lors de la conclusion du contrat en bouleversent l'économie au point qu'il devient financièrement très difficile pour le cocontractant de l'administration d'en poursuivre l'exécution comme prévu.

Dans un tel cas, indemnisation presque intégrale du surcoût lié à la situation d'imprévision.

Cette théorie a vocation à couvrir les aléas économiques. Elle est consacrée par **CE, 30 Mars 1916, Compagnie générale d'éclairage du gaz de Bordeaux**.

=> En l'espèce, 1^{er} GM et explosion du prix du charbon

=> Ici, la théorie de l'imprévision donne droit à une indemnisation à hauteur du surcoût lié à la situation d'imprévision (le marché aurait pu augmenter considérablement sans l'imprévision).

Précisions venues par la suite:

- Cette théorie avait au départ uniquement vocation à couvrir les aléas économiques. Par la suite, il a pu arriver que le juge y ait recours pour couvrir les aléas naturels ou encore des aléas administratifs non couverts par le fait du prince

- **CE, Section, 5 Nov. 1982, Propétrol**: l'Etat d'imprévisions ne libère nullement le cocontractant de son obligation d'exécution du contrat.

=> Car imprévision ≠ force majeure (imprévisible + extérieur + irrésistible).

- => S'il arrête d'exécuter, le cocontractant perd son droit à l'indemnité d'imprévision.
- => ⚠ Elle ne vaut pas pour tous les contrats administratifs mais que pour les contrats conclus pour les besoins de l'exécution des SP. Elle est donc justifiée par la continuité du SP.

Théorie aussi connue des privatistes (adoption par la JP de la CASS puis dans le Code civil avec la réforme du droit des contrats et obligations opérées par le 10 Fév. 2016).

Dans les faits, cette théorie ne joue que rarement pour plusieurs raisons: les situations d'imprévision sont rares + dans la plupart des contrats administratifs, il existe des clauses prévoyant l'indemnisation du cocontractant en cas d'aléa économique (clause de révision du prix du marché par ex.).

Ex. Guerre en Russie: le CE rends un avis le 15 Sept 2022 où il rappelle que les situations engendrées (augmentation du prix des énergies) laissent place à une indemnisation au moins partielle des hausses de prix. CEn revanche, l'arrêt propétrol a été tempéré en ajoutant que cette théorie est temporaire: si cette situation tends à devenir définitive, l'administration doit réviser le contrat (CE? Compagnie des tramways de Cherbourg).

Chapitre 2: Les actes administratifs unilatéraux

Le contrat naît d'un échange de consentement quand l'acte unilatéral naît de l'expression d'une seule volonté qui s'imposera au destinataire de l'acte. Ce procédé est caractéristique de la puissance publique: c'est un procédé de commandement.

§1- L'identification de l'Acte administratif unilatéral

Un acte administratif unilatéral est avant tout un acte juridique qui a donc nécessité de produire des effets de droit. Il faut en analyser la terminologie:

- Acte. Il produit des effets de droit. Un écrit qui n'a pas cet objet n'est donc pas un AAU.
- Ex. Arrêté autorisant le père Noël à voler au dessus de la commune
- Unilatéral = il naît juridiquement d'une seule volonté mais peut être pris par plusieurs personnes (ex. Acte multimunicipal)
- Administratif = qui émane de l'administration.

C'est le critère administratif qui pose problèmes et que nous détaillons.

A) LES ACTES UNILATÉRAUX NON ADMINISTRATIFS DES PERSONNES PUBLIQUES

PdR, 1erM, Ministres via les décrets et décrets ministériels prennent soit des AA soit des actes de gouvernement. S'ils ont la même forme, il n'existe pas de critère pour les distinguer (depuis l'arrêt du **tribunal des conflits Prince Napoléon** qui anéantit le précédent critère du mobile politique {acte de gouvernement = acte dont le but est un mobile politique}).

La distinction est en revanche importante car les actes de gouvernement ne sont pas susceptibles de recours.

A défaut de critères opérationnels, la JP a pu distinguer des actes de gouvernement en les rattachant toujours à un des deux domaines suivants:

- Relations entre les pouvoirs publics constitutionnels

Ex. Décret de dissolution de l'AN (**CE, 20 février 1989, Allain**), décret de promulgation des lois (**CE 3 novembre 1933, Desreumaux**)...

- La conduite des relations internationales: ratification d'un traité, envoyer des forces militaires à l'étranger, reprendre les essais nucléaires... sont des actes gouvernementaux.

⚠ Il y a des actes qui sont en lien avec la conduite des relations internationales mais considérés comme détachables de la conduite de relations internationales { ils ne sont pas suffisamment en lien}.

Ex. **CE, 3 Oct. 2018, Tamazount**: Les accords d'Evian prévoient le rapatriement des français algériens (pieds noirs) mais pas les Harkis (sympathisants algériens à la cause française), ceux qui rentrent ne sont pas accueillis de manière digne (camps ect.). Lorsque l'action politique, ils ont donc tenté de demander réparation du préjudice que la France a donné à l'arrêt Harki. Le CE a estimé que s'agissant de la décision de les abandonner en Algérie, il s'agit d'un acte de gouvernement; pour les mesures prises ensuite par le gouvernement vis à vis des Harkis venus en France, le CE a estimé qu'il s'agissait bien ici d'AAU dans la mesure où l'acte est détachable de la conduite des RI.

=> réparation à hauteur de 1000€/an (tarif pour réparation de détention dans des conditions indignes) => Face condamnée par CEDH.

B) LES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATÉRAUX DES PERSONNES PRIVÉES

Il n'est pas exclu qu'une personne chargée de SP ou délégataire de SP puisse rédiger des AAU. Arrêt de principe **CE, 31 Juillet 1942, Monpeurt**. Les conditions posées sont variables selon si la personne privée gère un SPA ou un SPIC:

- SPA = **CE, 13 Janv. 1961, Magnier**: L'acte doit entrer dans le champ de la mission de SP + l'acte doit révéler la mise en oeuvre de prérogatives de puissances publiques (s'impose au destinataire).

Ex. Acte prit par la FIA, comme internationale, ne relève pas d'un SP donc ø un AAU.

Ex. Fédérations agréées ne sont qu'agréées, pas délégataires de SP. Mais d'autres sont bien elles délégataires (FFF), on leur confie la gestion du SP (organisation des compétitions officielles + sélection des sportifs qui vont représenter la France) et un monopole de droit (aucune autre personne ne peut sélectionner pour les compétitions internationales = s'impose au destinataire).

Ex. Règlement de la coupe de France de football est un AAU (**CE, Section, 22 Nov. 1975, FIFAS**).

Ex. Les sanction disciplinaires prononcées par les fédérations délégataires sont des AAU (**CE, 26 Nov. 1976, Fédération française de cyclisme**).

Ex. Règlement relatif à la répartition des redevances issues des droits TV entre les clubs n'est PAS un AAU car n'entre pas dans le champ de la mission de SP (**CE, 28 Oct. 2021, Sté En avant Guingamp**).

- SPIC = **Tribunal des conflits, 15 Janv. 1968, époux Barbier**: Doivent être réglementaires + porter sur l'organisation ou le fonctionnement du service.

§2- La classification des AAU

A) LES AAU DÉCISOIRES ET NON DÉCISOIRES

Acte décisoire = modifie l'ordonnancement juridique (modifie une règle un droit ect.).

Acte non décisoire = ne modifie pas l'ordonnancement.

Ex. Avis, recommandation...

Pendant longtemps, la JP considérait que les actes non décisores ne pouvaient faire l'objet d'un recours devant le juge administratif. Progressivement, la tendance change jusqu'à **CE, Section, 12 Juin 2020, Gisti**.

1. Les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déferés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.

Critère de recevabilité de l'action en justice = effet notable susceptible sur les droits ou la situation des personnes à qui il s'adresse.

Ex. **CE, 2016, Société Fairvesta**: L'autorité des marchés financiers publie une mise en garde qui est susceptible de produire des effets notables sur les sociétés dont Fairvesta.
Gisti concerne avant tout des documents de portée générale

B) LES ACTES RÉGLEMENTAIRES ET INDIVIDUELLES

1. Décision réglementaire: qui concerne tt le monde (portée générale et impersonnelle).
2. Décision individuelle: ne concerne que des personnes nommées.
Ex. Sanction disciplinaire
3. Décision ni réglementaire ni individuelle
Ex. Déclaration d'utilité publique dans le cadre d'une expropriation.

⚠ Pour déterminer cette classification, il faut bien regarder le contenu même de l'acte et non pas la personne qui le prend.

Ex. Décret de nomination d'un haut fonctionnaire par le Premier ministre.

C) LES DÉCISIONS EXPLICITES ET LES DÉCISIONS IMPLICITES

Les décisions implicites se déduisent généralement du silence de l'administration. Au bout d'un certain temps (généralement 2 mois parfois plus), le silence vaut soit décision implicite de refus soit décision implicite d'acceptation.

En principe, le silence l'administration vaut acceptation mais le principe connaît énormément d'exceptions, il vaut donc refus dans la plupart des cas.

D) LES ACTES FAISANT GRIEF ET LES ACTES NE FAISANT PAS GRIEF

Les acte faisant grief sont susceptible d'un recours en annulation devant le juge administratif vs. Acte ne faisant pas grief qui ne sont pas susceptibles de recours.

En principe, un recours en annulation dirigé contre un acte administratif unilatéral décisoire est recevable, et à l'inverse, un recours dirigé contre un acte non décisoire est irrecevable. La réalité est plus complexe.

En effet, certains actes décisores sont considérés comme trop insignifiants pour embêter le juge, ce sont les MOI (mesures d'ordre intérieur).

Elles concernent la vie intérieure des administrations et SP.

Ex. Agent affecté sur un posté et déplacé ailleurs.

Ex. Affectation à un groupe de TD.

Les MOI existent toujours mais depuis une trentaine d'année, ils se sont légèrement vidés de leur substance. Le contenu de la catégorie s'est rétrécit (actes qui en étaient mais plus maintenant).

Ex. **CE, 17 Fev. 1995, Arrêts Hardoin et arrêt Marie** : La sanction de mise au mitard d'un prisonnier était avant considérée MOI mais plus maintenant (arrêt Marie). Dans l'arrêt Hardoin, c'est un militaire mis aux arrêts militaires (prison interne) qui étaient avant considéré MOI et maintenant non.

A travers 3 arrêts rendus par **CE, ass., 14 Dec. 2007: Payet, Planchenault, Boussouar**, ce constat s'est étendu l'ensemble des mesures prises à l'égard des détenus.

Ces arrêts ne relèvent pas ici de l'évolution d'une sensibilité sur ce qui mérite le procès mais posent bien des critères: l'importance de la mesure IN ABSTRACTO + importance IN CONCRETO (atteinte aux droits fondamentaux du détenu).

Ex. Transfert d'un établissement pour peinte (= prison pour longues peinte) à un autre. In ABSTRACTO pas grave mais IN CONCRETO peut avoir des conséquences sur les droits et libertés de la personne (ex. Canaque transféré de Nouméa à Paris, ne voit plus sa famille => atteinte à au droit de vie familiale).

La mesure qui semble IN ABSTRACTO être MOI n'en n'est donc pas une IN CONCRETO.

Section 2 Les régime des actes administratifs unilatéraux

§1- Le privilège du préalable

= les actes unilatéraux ont un caractère exécutoire: les administrés doivent les exécuter sans saisie préalable du juge pour que le juge ordonne aux administrés d'y obéir.

Qualifiée de règle fondamentale du droit public par le CE dans l'arrêt du Huglo (CE, **assemblée**, 2 Juillet 1982).

Conséquence, par ce qu'ils sont présumés légaux, c'est à l'administré de saisir le juge et donc mener l'action en justice et apporter la preuve.

=> Présomption de légalité des AA. Elle est d'autant plus complexe pour les administrés car le recours contentieux n'a pas, en principe, d'effet suspensif.

Caractère exécutoire ≠ exécution d'office (par la force). Si elle veut utiliser la force, elle doit recourir au juge pour en avoir l'autorisation.

Ca n'est possible que par exception: **TC, 2 Dec. 1902, Société immobilière de Saint-Just**:

- Lorsque l'urgence le commande (ex. Pompiers)
- Lorsque la loi le prévoit (ex. Loi d'état d'urgence sanitaire)
- Le cas où l'administration n'a aucune autre voie de droit pour contraindre l'administré à s'exécuter.

§2- La procédure administrative non contentieuse

Contentieuse = procès

Non contentieuse = élaboration et disparition des AAU.

On cherche un dosage entre inégalité et garantie:

- Le motivation de l'AAU: il doit en principe être motivé mais il y a de nombreuses exceptions qui découlent de la **Loi sur la motivation des actes administratifs unilatéraux de 1979** ainsi, il y a une liste d'actes qui doivent être motivés

Ex. Restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police, les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice droit (retirer la bourse), les décisions qui infligent une sanction

- Principe du contradictoire: L'administration doit, dans certains cas, entendre au préalable les personnes concernées par la décision.

Ex. Les sanctions disciplinaires,

=> découle du principe général du droit à la défense

- La participation du public:

Ex. Charte de l'environnement prévoit que le public doit être associé aux décision susceptibles d'avoir un effet important sur l'environnement.

Règles concernant le retrait et l'abrogation des actes:

Différent suivant s'ils réglementaires ou individuels, créateurs de droit ou non. Lorsque l'administration supprime un acte qui avait accordé un droit à quelqu'un, c'est plus complexe.

Il y a des délais, généralement 4 mois mais peut être plus (avoir eu son doctorat en plagiant => on retire le diplôme de snanées après)

Normalement deux conditions pour les retirer: 4 mois, pas au delà + que l'acte soit illégal